PRO LEGES

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO

- Atualizado em 25/07/2023

PARA CONCURSOS

SUMÁRIO

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO 2
CONCEITOS FUNDAMENTAIS E MODALIDADES DE DISCRIMINAÇÃO 2
DIREITO À IGUALDADE RACIAL 14
DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIAP+ 17
DIREITOS DAS MULHERES 22
DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 28

Para saber se o material foi atualizado, clique aqui e confira a data da capa (se for posterior a 11/04/2023, houve alteração no conteúdo):

- Link: https://www.proleges.com.br/account/antidiscriminatorio

Legenda dos grifos:

- AMARELO – DESTAQUE
- VERDE – EXCEÇÃO, VEDADO ou ALGUMA ESPECIFICIDADE
- AZUL – GÊNERO, PALAVRA-CHAVE ou EXPRESSÃO

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO



AUTOR: MARCO TORRANO
INSTAGRAM: @MARCOAVTORRANO/@PROLEGES
E-MAIL: MARCOAVTORRANO@GMAIL.COM

CONCEITOS FUNDAMENTAIS E MODALIDADES DE DISCRIMINAÇÃO

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

1.	**O QUE SE ENTENDE POR DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO?** • Segundo Adilson Moreira (em sua obra mais completa sobre o tema): "Podemos definir o Direito Antidiscriminatório a partir de diferentes parâmetros. Ele pode ser visto, quanto à sua natureza específica, como um campo jurídico composto por uma série de normas que pretendem reduzir ou eliminar disparidades significativas entre grupos, um dos objetivos centrais dos textos constitucionais das sociedades democráticas. Essa meta pode ser alcançada por meio da criação de um sistema protetivo composto por normas legais e iniciativas governamentais destinadas a impedir a discriminação negativa, forma de tratamento desvantajoso intencional e arbitrário, e também por iniciativas públicas ou privadas destinadas a promover a discriminação positiva, ações voltadas para a integração social de minorias. (...) Esse campo pretende então estabelecer uma relação igualitária entre segmentos sociais, um objetivo do constitucionalismo contemporâneo que só pode ser atingido a partir de mecanismos legais e políticos que procuram combater a discriminação. Assim, as normas que formam esse campo jurídico operam a partir da análise conjunta das relações estruturais entre dois elementos centrais; a igualdade e a discriminação. Ele constitui um estudo das normas que direta ou indiretamente são relevantes para a construção de um sistema protetivo, o que tem relevância em sociedades que, mesmo sendo reguladas por regimes democráticos, ainda estão estruturadas a partir de relações hierárquicas de poder entre seus diferentes segmentos. A igualdade preconizada na legislação desses países só pode ser alcançada com a identificação e a eliminação dos mecanismos que impedem o reconhecimento da igual humanidade das pessoas" (Tratado de direto antidiscriminatório, São Paulo, Contracorrente, 2020, p. 50).
2.	**QUAL É O OBJETIVO DO DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO?** • Segundo Adilson Moreira (em sua obra mais completa sobre o tema): "O Direito Antidiscriminatório compreende então um aparato teórico, um corpo de normas jurídicas, precedentes jurisprudenciais, medidas legislativas e políticas públicas necessárias para a consecução de um programa de transformação social presente nos textos constitucionais das democracias contemporâneas. Ele está estruturalmente relacionado com o objetivo de construção de uma sociedade justa na qual as pessoas possam ter acesso aos meios necessários para poderem viver de forma digna. Isso inclui o gozo do mesmo nível de respeitabilidade social e também das condições materiais necessárias para a inserção social. O ideal da antidiscriminação não designa apenas um princípio que proscreve atos arbitrários, mas sim um projeto social que pretende expandir a prática democrática por meio da promoção de medidas inclusivas e da construção de uma cultura social baseada no reconhecimento de todos como atores que podem atuar de forma competente no espaço público. O avanço da democracia requer então a construção de um sistema protetivo que possa garantir os meios para que a criação de uma sociedade democrática seja realizada, o que só pode acontecer quando mecanismos que promovem hierarquias sociais são devidamente identificados e eliminados." (Tratado de direto antidiscriminatório, São Paulo, Contracorrente, 2020, p. 41).

• Portanto, o objetivo do Direito Antidiscriminatório é combater práticas excludentes que impactam os indivíduos independentemente do *status* social.

3.

PRECONCEITO RACIAL

• O preconceito racial é o juízo baseado em estereótipos sobre indivíduos.
• Atua no **âmbito interno**, **subjetivo** e **abstrato** do agente.

3.

DISCRIMINAÇÃO RACIAL

• A discriminação racial é a prática de tratamento discriminatório sobre indivíduos.
• É ato objetivo, externalizado direta ou indiretamente.
• É a **materialização do preconceito**.

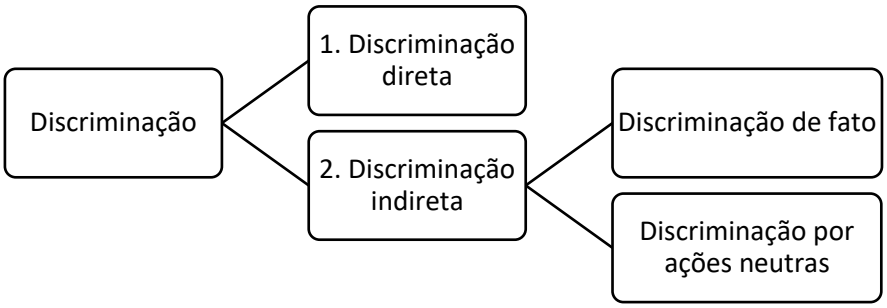
DISCRIMINAÇÃO RACIAL **DIRETA (intencionalidade explícita)**	DISCRIMINAÇÃO RACIAL **INDIRETA (aparentemente neutro)**
É o repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos, motivado pela condição racial (ex: proibir a entrada de negros, judeus e muçulmanos no país "x"). Envolve **intencionalidade** (a pessoa discrimina a outra de maneira voluntária e consciente, utilizando para isso um critério proibido por lei) e **arbitrariedade** (conduta abusiva, violenta, ilegal).	É marcada pela ausência de intencionalidade explícita de discriminar pessoas. Fala-se, aliás, em processos irracionais inconscientes ou discriminação inconsciente / invisível. Ocorre quando um critério (conduta, prática ou dispositivo) **aparentemente neutro** tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico. Perceba que na discriminação indireta inexiste o elemento central da discriminação direta, qual seja, a intenção explícita de discriminação. Mas exige, para sua configuração, um impacto desproporcional sobre determinado grupo (**teoria do impacto desproporcional / *disparate impact***).

➥ ***O que se entende por teoria do impacto desproporcional?*** "A discriminação indireta é mais sutil: consiste na adoção de critério aparentemente neutro (e, então, justificável), mas que, na situação analisada, possui impacto negativo desproporcional em relação a determinado segmento vulnerável. A discriminação indireta levou à consolidação da teoria do impacto desproporcional, pela qual é vedada toda e qualquer conduta (inclusive legislativa) que, ainda que não possua intenção de discriminação, gere, na prática, efeitos negativos sobre determinados grupos ou indivíduos" (RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos..., Saraiva, 2021).

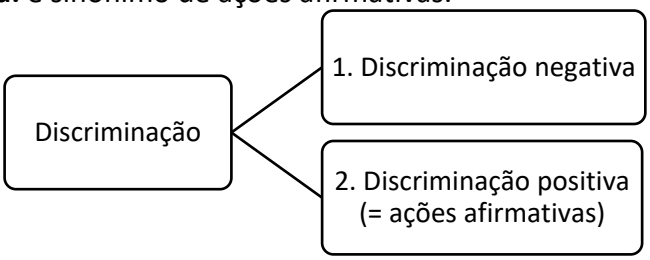
➥ **Aprofundando um pouco mais sobre a teoria do impacto desproporcional:** a teoria do impacto desproporcional é sistematizada com base nos conceitos de discriminação de fato e discriminação por ações neutras (NASCIMENTO, Filippe. Manual de humanística..., Juspodivm, 2022, p. 735):

i) discriminação de fato: ocorre quando a realidade é desigual e os autores envolvidos poderiam agir para encerrar a desigualdade, mas, por omissão, mantém a desigualdade de fato;

ii) discriminação por ações neutras: acontece quando há uma norma aparentemente neutra, que, na sua aplicação, efetivamente irá discriminar uma pessoa ou grupo, ou seja, a mera aplicação da norma leva à discriminação.



➥ **Discriminação negativa vs. discriminação positiva (= ações afirmativas):**
i) discriminação negativa: determina as pessoas a uma situação de inferioridade em relação a outras por questões ligadas a etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual etc.;
ii) discriminação positiva: é sinônimo de ações afirmativas.



4.

RACISMO

• O racismo ocorre quando há discriminação (de modo sistemático e geral), tendo como fundamento o aspecto étnico (etnia/raça).
• É de caráter sistêmico. Racismo é diferente de apenas um ato discriminatório. Pois o racismo se identifica como um processo de imposição de desvantagens a grupos de etnias/raças diferentes.

5.

SEXISMO

• O sexismo ocorre quando há discriminação de modo sistemático e geral em razão do sexo e gênero.
• Sexo é determinado com o nascimento.
• Gênero é o conjunto de valores socialmente construídos sobre características e comportamentos que uma sociedade designa para as pessoas de cada sexo (homens e mulheres).
• O sexismo, em regra, está ligado a estereótipos e papéis de gênero.
• Exemplo: desigualdade praticada pelo grupo masculino contra o grupo feminino.

> CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER (CEDAW): DECRETO 4.377/2002
> PARTE I - Artigo 1º
> Para os fins da presente Convenção, a expressão "**DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER**" significará toda a distinção, exclusão ou restrição **baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado** prejudicar ou anular **o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil**, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.

6.

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

• A intolerância religiosa ocorre quando há discriminação de modo sistemático e geral em razão do gênero.

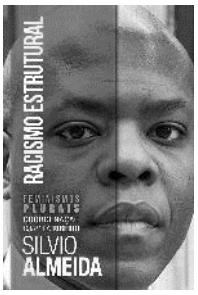
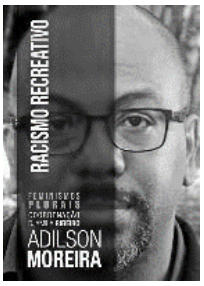
7.

LGBTQIA+fobia

• O LGBTQIA+fobia ocorre quando há discriminação de modo sistemático e geral em razão das afetividades humanas.

Questões
☑ **(Defensor DPERS 2022 Cespe correta)** Para falar de racismo, é preciso antes diferenciar o racismo de outras categorias que também aparecem associadas à ideia de raça: preconceito e discriminação. Podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Embora haja relação entre os conceitos, o racismo difere do preconceito racial e da discriminação racial. O preconceito racial é o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a determinado grupo racializado, o que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. Considerar negros violentos e inconfiáveis, judeus avarentos ou orientais "naturalmente" preparados para as ciências exatas são exemplos de preconceitos. A discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Portanto, a discriminação tem como requisito fundamental o poder — ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força —, sem o qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Assim, a discriminação pode ser direta ou indireta. A discriminação direta é o repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos, motivado pela condição racial, exemplo do que ocorre em países que proíbem a entrada de negros, judeus, muçulmanos, pessoas de origem árabe ou persa, ou ainda lojas que se recusam a atender clientes de determinada raça. Já a discriminação indireta é um processo em que a situação específica de grupos minoritários é ignorada — discriminação de fato — ou sobre a qual são impostas regras de "neutralidade racial" sem que se leve em conta a existência de diferenças sociais significativas — discriminação pelo direito ou discriminação por impacto adverso. A discriminação indireta é marcada pela ausência de intencionalidade explícita de discriminar pessoas. Isso pode acontecer porque a norma ou prática não leva em consideração ou não pode prever de forma concreta as consequências da norma. Silvio Almeida. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais). Editora Jandaíra. Edição do Kindle (com adaptações). Com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue o item que se segue. O texto trata os termos "racismo", "discriminação racial" e "preconceito racial" como semanticamente relacionados, embora distintos entre si.

ESPÉCIES DE RACISMO	
1.	**Racismo individualista**
	O racismo individualista trata o racismo como uma espécie de "patologia" social. Um fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou coletivo, atribuído a grupos isolados; ou, ainda, uma "irracionalidade", cuja providência mais adequada a ser tomada é no campo jurídico (sanção penal ou civil). **Não haveria sociedades ou instituições racistas, mas indivíduos racistas, que agem isoladamente ou em grupo**. O racismo é notado na forma de **discriminação direta**.
2.	**Racismo institucional**
	O racismo institucional é o resultado do **mau funcionamento das instituições**, que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios a partir da raça. **Admite-se aqui, portanto, o racismo como discriminação indireta**. Por serem as instituições lugares de produção de sujeitos é necessário que haja medidas de "correção" dos mecanismos institucionais, como ações afirmativas que aumentem a representatividade de minorias raciais e que alterem a lógica interna dos processos decisórios. ☑ **(Promotor MPEPA 2023 Cespe correta)** Em relação ao racismo institucional e aos seus reflexos no procedimento de reconhecimento fotográfico em sede policial, assinale a opção correta. O erro de reconhecimento de pessoa negra no procedimento de reconhecimento fotográfico é reflexo do racismo que se expressa e se estrutura por meio da seletividade penal em sede policial, o que resulta na condenação e no sofrimento de pessoas negras inocentes.
3.	**Racismo estrutural**

	O racismo estrutural é uma **decorrência da própria estrutura social**, **ou seja, do modo "normal" com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional**. Aqui, considera-se que comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo *racismo é regra e não exceção*. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, **torna-se imperativo pensar sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas**. Pela complexidade das ligações que apresenta com a política, a economia e o direito, é importante falar mais sobre o *racismo estrutural*. 
4.	**Racismo recreativo** A expressão foi cunhada por Adilson José Moreira. O racismo recreativo é uma política cultural que referenda por meio do humor a ideia de que negros não são atores sociais competentes. Isso permite que pessoas brancas hostilizem minoriais sociais sem perder uma imagem social positiva. Nas palavras do autor da expressão (Adilson José Moreira, 2019, p. 31):  > Esse conceito [de raicsmo recreativo] designa um tipo específico de opressão racial: a circulação de imagens derrogatórias que expressam desprezo por minoriais raciais na forma de humor, fator que compromete o status cultural e o estatus material dos membros desses grupos. Esse tipo de marginalziação tem o mesmo objetivo de outras formas de racismo: legitimar hierarquias raciais presentes na sociedade brasileira de forma que oportunidades sociais permaneçam nas mãos de pessoas brancas. Ele contém mecanismos que também estão presentes em outros tipos de racismo, embora tenha uma **caracterísitca especial: o uso do humor para expressar hostilidade racial**, estratégia que permite a perpetuação do racismo, mas que protege a imagem social de pessoas brancas. Exemplos práticos de racismo recreativo como política cultural (2019): *Tião Macalé, o feio; Mussum, o bêbado; Vera Verão, a bicha preta; Adelaide, a desvairada*.[1]
5.	**Racismo ambiental** A expressão "racismo ambiental" (racismo meio ambiental ou ecorracismo) surgiu no ano de **1981** pelo líder afro-americano de direitos civis Benjamin Franklin Chavis Jr. A expressão surgiu em um contexto de manifestações do movimento negro contra injustiças ambientais. O autor da expressão, Benjamin Franklin Chavis Jr., cunhou o termo para se referir à: "Discriminação racial no ataque deliberado às comunidades étnicas e minoritárias por meio de sua exposição à locais e instalações de resíduos tóxicos e perigosos, juntamente com a exclusão sistemática de minorias na elaboração, cumprimento e reparação das políticas ambientais".  ☑ **(Sociólogo Prefeitura de Betim/MG 2020 AOCP correta)** O ecorracismo ou racismo ambiental é utilizado por pesquisas que investigam a relação entre os problemas ambientais e as condições de vulnerabilidade social enfrentadas pela população negra.

➥ ALMEIDA, Sílvio Luiz de. Três concepções de racismo: individualista, institucional e estrutural. Disponível: https://bit.ly/3uwTbff.

➥ MOREIRA, Adilson. Racismo recreativo..., Pólen, 2019.

[1] Esses exemplos foram retirados da obra do Prof. Adilson José Moreira (2019, p. 98 a 116).

Casos contra o Brasil na CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos)

CASO SIMONE ANDRÉ DINIZ VS. BRASIL

• **Primeira vez que um país (membro da OEA) é responsabilizado na CIDH por racismo.**
• **Racismo institucional.** O Caso Simone André Diniz vs. Brasil se tornou paradigma do fenômeno racismo institucional.
• **Resumo do caso:** Gisele Mota da Silva publicou nos Classificados, do jornal Folha de S. Paulo, o seu interesse em contratar uma empregada doméstica, a qual deveria ter "cor branca". Simone André Diniz, mulher negra, ligou para o número indicado e se apresentou como candidata, mas foi recusada pela empregadora por sua cor. Sentindo-se discriminada, Simone apresentou *notitia criminis* por meio da Subcomissão do Negro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP. Foi instaurado inquérito policial com base no art. 20 da Lei 7.716/1989. Mas o MP manifestou pelo arquivamento e o Poder Judiciário homologou. A referida Subcomissão da OAB levou o caso para a CIDH. A CIDH entendeu que excluir uma pessoa do acesso ao mercado de trabalho por sua raça constitui ato de discriminação racial, violando o art. 24 da CADH.

> ARTIGO 24
> Igualdade Perante a Lei
> Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação, a igual proteção da lei.

• **Recomendações da CIDH ao Brasil:**
1. Reparar plenamente a vítima Simone André Diniz, considerando tanto o aspecto moral como o material, pelas violações de direitos humanos determinadas no relatório de mérito e, em especial,
2. Reconhecer publicamente a responsabilidade internacional por violação dos direitos humanos de Simone André Diniz;
3. Conceder apoio financeiro à vítima para que esta possa iniciar e concluir curso superior;
4. Estabelecer um valor pecuniário a ser pago à vítima à título de indenização por danos morais;
5. Realizar as modificações legislativas e administrativas necessárias para que a legislação anti-racismo seja efetiva, com o fim de sanar os obstáculos demonstrados nos parágrafos 78 e 94 do presente relatório;
6. Realizar uma investigação completa, imparcial e efetiva dos fatos, com o objetivo de estabelecer e sancionar a responsabilidade a respeito dos fatos relacionados com a discriminação racial sofrida por Simone André Diniz;
7. Adotar e instrumentalizar medidas de educação dos funcionários de justiça e da polícia a fim de evitar ações que impliquem discriminação nas investigações, no processo ou na condenação civil ou penal das denúncias de discriminação racial e racismo;
8. Promover um encontro com organismos representantes da imprensa brasileira, com a participação dos peticionários, com o fim de elaborar um compromisso para evitar a publicidade de denúncias de cunho racista, tudo de acordo com a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão;
9. Organizar Seminários estaduais com representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e Secretarias de Segurança Pública locais com o objetivo de fortalecer a proteção contra a discriminação racial e o racismo;
10. Solicitar aos governos estaduais a criação de delegacias especializadas na investigação de crimes de racismo e discriminação racial;
11. Solicitar aos Ministérios Públicos Estaduais a criação de Promotorias Públicas Estaduais Especializadas no combate ao racismo e a disriminação racial;
12. Promover campanhas publicitárias contra a discriminação racial e o racismo.

• **Atenção:** este caso foi na **CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos)**, e não na Corte IDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos).

☑ **(Defensor DPERJ 2021 FGV correta)** No caso Simone André Diniz, uma empregada doméstica teve recusada a sua candidatura ao emprego por ser negra. O caso levado à justiça brasileira foi arquivado. Ao

analisar o tema, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos entendeu que: o fato de não ter sido aberta ação penal para apuração de denúncia de discriminação racial viola o direito à não discriminação e ao acesso à justiça.

Questões
☑ **(Defensor DPEPB 2022 FCC correta)** Situação frequente na qual alguns indivíduos em meios de comunicação veiculam discurso que incita ao desprezo a práticas fundadas em religiões de matriz africana é definida como racismo estrutural, que pode gerar danos morais coletivos e individuais, sendo que a responsabilidade pode atingir os indivíduos que praticaram os atos discriminatórios e também os Entes Públicos que não coibirem tal conduta.
☑ **(Procurador do Trabalho MPT 2020 correta)** O chamado racismo institucional ou sistêmico pode ser compreendido como mecanismo estrutural que garante a exclusão seletiva de grupos racialmente subordinados, a exemplo, na realidade brasileira, de negros, indígenas e ciganos.
☑ **(Defensor DPERJ 2021 FGV correta)** "O recrudescimento cautelar do sistema de controle brasileiro refletiu os objetivos reais e ideais de um país racista que tinha como problema maior a questão negra, calcada em termos genocidas como condição de sobrevivência da sua falsa branquidade. Contexto que impôs uma cisão em nosso Direito Penal: ao lado do Direito Penal declarado para os cidadãos, alicerçado no Direito Penal do fato construído às luzes do Classicismo, o Direito Penal paralelo para os "subcidadãos", legitimado no Direito Penal do autor consolidado pela tradução marginal do paradigma racial-etiológico, que, por sua vez, situa seu fundamento na periculosidade que exala dos corpos negros, um sistema outrora identificado por Lola Aniyar de Castro (2005, p. 96) como "subterrâneo" que aqui jamais se ocultou, sendo operacionado sob os olhos de quem quiser enxergar." (GÓES, Luciano. Abolicionismo penal? Mas qual abolicionismo, "cara pálida"?. Revista InSURgência. Brasília. Ano 3. v.3. n.2. 2017. Pg. 98). Considerando a afirmativa acima, é possível compreender o fenômeno do encarceramento em massa no Brasil, sob o ponto de vista empírico e teórico, a partir da correlação entre: o racismo estrutural e o direito penal do inimigo.
☑ **(Advogado Prefeitura de Formiga/MG 2020 Consulplan correta)** O racismo institucional é o fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado às pessoas em virtude de sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Ele se manifesta em normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, os quais são resultantes do preconceito racial, uma atitude que combina estereótipos racistas, falta de atenção e ignorância. Em qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações. Das alternativas a seguir, assinale a que evidencia manifestação do racismo institucional. Concepção pela qual se conferem privilégios e desvantagens a determinados grupos em razão da raça, normalizando estes atos por meio do poder e da dominação.
☑ **(Psicólogo Prefeitura de Salvador/BA 2019 FGV correta)** A prática de racismo institucional é marcada pelo tratamento diferenciado e desigual, efetivada em estruturas públicas e privadas, indicando a falha do Estado em prover assistência igualitária aos diferentes grupos sociais.
☑ **(Defensor DPEPR 2022 AOCP adaptada correta)** No dia 12/11/2021, a 1ª Subdefensora Pública-Geral da Defensoria Pública do Paraná, mulher negra, lançou o programa "Letrando em Pretoguês - Programa Permanente de Educação Antirracista", cuja frentes de atuação serão múltiplas, com: oferta de cursos de capacitação continuada e palestras sobre racismo e como aprimorar o atendimento da DPE-PR à população negra; implementação ou ampliação das políticas afirmativas internas; criação de comissões voltadas à discussão das questões étnico-raciais; incentivo e destaque ao protagonismo negro dentro da instituição e elaboração de censos étnicos para subsidiar as ações a serem implementadas, entre outras iniciativas. Considerando esse fato a partir da leitura da obra Racismo Estrutural, de Silvio de Almeida, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. O programa demonstra uma frente de práticas antirracistas pela instituição, etapa crucial para o combate ao racismo estrutural. E na perspectiva do racismo como processo político, pode-se

afirmar que o programa enfrenta a dimensão institucional da politicidade do racismo, sem que isso reduza o racismo a uma concepção meramente institucional.

☑ **(Defensor DPEBA 2021 FCC correta)** Lúcio, um homem negro, foi abordado por seguranças de uma rede de Supermercados de Salvador, no interior de estabelecimento comercial, e acusado de subtrair mercadorias que estavam expostas à venda. Lúcio foi conduzido a uma sala reservada, onde foi agredido e exigido o pagamento de certa quantia em dinheiro para ser liberado. Como não teve condições de pagar a quantia exigida, os seguranças o entregaram para terceiros, que o torturaram e mataram. Indignados com a situação, populares procuraram a Defensoria Pública da Bahia para obter informações e para a adoção de providências judiciais cabíveis. Nessas circunstâncias, a orientação dada pela Defensoria Pública deve sustentar que a pessoa jurídica tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao indivíduo e seus familiares, sem prejuízo do cabimento de ação civil pública proposta pela Defensoria Pública para o ressarcimento de danos morais coletivos em razão de racismo estrutural.

☑ **(Promotor MPEPA 2023 Cespe correta)** No que tange ao Estatuto da Igualdade Racial e ao racismo estrutural observado nos quadros funcionais de empresas e instituições, assinale a opção correta. Cabe ao poder público promover ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas para a promoção da igualdade nas contratações e na ascensão profissional.

☑ **(Juiz Federal TRF4R 2022 correta)** Desigualdades e discriminações estruturais devem ser levadas em consideração por juízas e juízes na condução das audiências, na escuta das partes e de seus argumentos, bem como na produção da prova pericial, o que requer inclusive circunscrever quesitos que tracem as motivações decorrentes dos processos interseccionais de opressão, como gênero, raça e orientação sexual.

☑ **(Defensor DPESC 2021 FCC correta)** O "racismo estrutural", consoante Silvio Luiz de Almeida, é uma decorrência da forma com que se constituem as relações sociais, de modo que o direito faz parte da mesma estrutura social que o reproduz enquanto prática política e como ideologia.

☑ **(Defensor DPEMS 2022 FGV correta)** O discurso de ódio (*hate speech*) racial é a manifestação de ideias que incitam a intolerância e a discriminação de raça contra determinado grupo, extrapolando ilegalmente a liberdade de expressão, com violação à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Tal convenção prevê que os Estados-partes condenem a discriminação racial e comprometam-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem tardar, uma política de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e de promoção de entendimento entre todas as raças, e, para esse fim, cada Estado-parte: compromete-se a não encorajar, defender ou apoiar a discriminação racial praticada por uma pessoa ou uma organização qualquer.

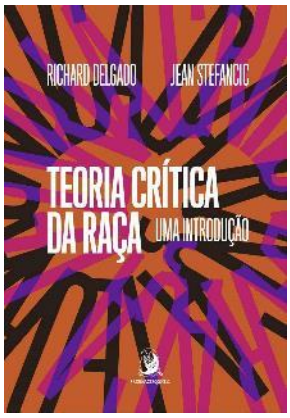
☑ **(Promotor MPEAM 2023 Cespe correta)** Em 2019, o quadro Orixás, da pintora brasileira Djanira da Motta e Silva, até então a principal obra de decoração do Salão Nobre do Palácio do Planalto, foi injustificadamente retirado do local e enviado para o arquivo do Planalto, deixando de ser exibido ao público. No que se refere a esse episódio e aspectos a ele relacionados, assinale a opção correta O MP pode averiguar se há fundamento jurídico para a abertura de investigação das circunstâncias que motivaram a retirada dessa obra do Salão Nobre do Palácio do Planalto, o que pode ser objeto de eventual inquérito civil público relativo a suspeita de racismo religioso contra as religiões de matriz africana no Brasil.

☑ **(Promotor MPESE 2022 Cespe correta)** Em relação aos casos Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde e Trabalhadores da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus Familiares, assinale a opção correta. Ambos os casos citados versaram sobre o racismo estrutural e interseccional, ou seja, pessoas pobres e negras escolhidas como trabalhadores em razão da sua situação de vulnerabilidade.

☑ **(Juiz Federal TRF3R 2022 correta)** A Cidade de São Paulo — vez que historicamente promoveu segregação sócio-espacial da população negra — evidencia característica sempre presente no racismo. Mais especificamente: "O privilégio racial no acesso à propriedade (...) deve ser

compreendido, portanto, como uma manifestação do racismo (...) que promove a segregação socioespacial da população negra (...). O racismo é fator (...) organizador das relações econômicas que afetam a ocupação do espaço urbano. Referida segregação socioespacial tem caráter cíclico ao condicionar indiretamente a forma de ocupação do espaço urbano da maioria da população negra, traduzida por zonas periféricas e desprovidas de infraestrutura adequada e de um entorno que oportunize uma melhor sociabilidade." (Anna Lyvia Roberto Custódio Ribeiro, 2020). Essa característica sempre presente no racismo o revela como "elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Em suma, O que queremos explicitar é que O racismo é a manifestação 'normal' de uma sociedade, e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de "anormalidade". O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea." (Silvio Luiz de Almeida, 2019). A essa característica ou fator sempre presente no racismo denominamos: Racismo estrutural.

O QUE SE ENTENDE POR "TEORIA CRÍTICA DA RAÇA"?



• É importante informar que **a "teoria crítica da raça" estava expressamente prevista no edital da DPESP/2023** e o mesmo edital indicou expressamente a obra de Richard Delgado e Jean Stefancic. Portanto, fique atento se o seu edital também menciona tal tema e tais autores.

• A **TEORIA CRÍTICA DA RAÇA (TCR)** é um coletivo de ativistas e acadêmicos empenhados em estudar e transformar a relação entre raça, racismo e poder.

> O movimento contempla muitas das mesmas questões que os discursos convencionais sobre direitos civis e os estudos étnicos abordam, mas as coloca em uma perspectiva mais ampla que inclui a Economia, a História, a conjuntura, os interesses coletivos e individuais e também as emoções e o inconsciente. Ao contrário do discurso tradicional dos direitos civis, que enfatiza o gradualismo e o progresso passo a passo, a teoria crítica da raça questiona os próprios fundamentos da ordem liberal, incluindo a teoria da igualdade, o discurso jurídico, o racionalismo iluminista e os princípios neutros do Direito Constitucional.
>
> ➥ Delgado, Richard; Stefancic, Jean. Teoria Crítica da Raça: uma introdução. Editora Contracorrente. Edição do Kindle.

• Origem: a teoria crítica da raça surgiu nos anos 70.

> A teoria crítica da raça se baseia em contribuições de dois movimentos anteriores, os estudos críticos do Direito e o feminismo radical, aos quais deve muito. Também se inspira em certos filósofos e teóricos europeus, como Antonio Gramsci, Michel Foucault e Jacques Derrida, bem como na tradição radical americana exemplificada por figuras como Sojourner Truth, Frederick Douglass, W. E. B. Du Bois, César Chávez, Martin Luther King Jr., e nos movimentos Black Power e Chicano dos anos 60 e início dos anos 70.
>
> ➥ Delgado, Richard; Stefancic, Jean. Teoria Crítica da Raça: uma introdução. Editora Contracorrente. Edição do Kindle.

• **ESCOLAS IDEALISTAS** vs. **REALISTAS/MATERIALISTAS (ou DETERMINISTAS ECONÔMICOS)**:

> Um dos grupos, que podemos chamar de "**idealista**", sustenta que o racismo e a discriminação são questões de pensamento, de categorização mental, de atitude e de discurso. A **raça é uma construção social**, não uma realidade biológica, dizem eles. Assim, podemos desarmá-la e privá-la de grande parte de seu veneno transformando o sistema de imagens, palavras, atitudes, sentimentos inconscientes, papéis e aprendizagem social pelos quais transmitimos uns aos outros

que certas pessoas são menos inteligentes, confiáveis, trabalhadoras, íntegras e americanas do que outras.

Uma outra escola de pensamento – a dos "**realistas**" ou **deterministas econômicos** – sustenta que, embora atitudes e palavras sejam importantes, o racismo é muito mais do que um repertório de opiniões desfavoráveis sobre membros de outros grupos. **Para os realistas, o racismo é um meio pelo qual a sociedade atribui privilégios e status.** As hierarquias raciais determinam quem recebe benefícios concretos, incluindo os melhores empregos, as melhores escolas e os convites para festas. Os membros dessa escola de pensamento apontam que o preconceito contra os negros nasceu com a escravidão e com a necessidade de força de trabalho por parte dos capitalistas. Antes disso, os europeus educados tinham, em geral, uma atitude positiva em relação aos africanos, reconhecendo que as civilizações africanas eram altamente avançadas, com amplas bibliotecas e centros de aprendizado. De fato, as civilizações do Norte da África foram pioneiras na Matemática, na Medicina e na Astronomia, muito antes que os europeus tivessem um conhecimento satisfatório dessas ciências.

➥ Delgado, Richard; Stefancic, Jean. Teoria Crítica da Raça: uma introdução. Editora Contracorrente. Edição do Kindle.

☑ **(Defensor DPESP 2023 FCC correta)** De acordo com Delgado e Stefancic, na obra "Teoria Crítica da Raça", os pensadores da teoria crítica da raça – e, de certo modo, os ativistas dos direitos civis em geral – podem ser divididos em dois grupos ou escolas. Para uma dessas escolas, o racismo seria um meio pelo qual a sociedade atribui privilégios e status. Para ela, as hierarquias raciais determinam quem recebe benefícios concretos como, por exemplo, os melhores empregos. Segundo os autores, trata-se da escola de pensamento dos realistas ou deterministas econômicos.

• Crítica ao liberalismo e **CRÍTICA À NEUTRALIDADE RACIAL**:

Os acadêmicos da teoria crítica da raça não aceitam o liberalismo como uma abordagem adequada para enfrentar os problemas raciais dos Estados Unidos. Muitos liberais acreditam na neutralidade racial e nos princípios neutros do Direito Constitucional. Eles acreditam na igualdade, especialmente na igualdade de tratamento para todas as pessoas, independentemente de sua história ou condição atuais. Alguns até chegaram a se convencer de que com a eleição de Barack Obama iniciávamos uma fase pós-racial de desenvolvimento social. (...)A neutralidade racial pode ser louvável quando, por exemplo, um tomador de decisões do governo se recusa a ceder aos preconceitos locais. Mas pode ser perversa quando, por exemplo, impede que se levem em conta diferenças para auxílio a pessoas carentes. Uma versão extrema da neutralidade racial, encontrada em certas manifestações atuais da Suprema Corte, alega que é errado para o Direito considerar qualquer aspecto relativo à raça, mesmo que seja para reparar um erro histórico. **Os teóricos da teoria crítica da raça (ou "crits", como às vezes são chamados) afirmam que a neutralidade racial nos permitirá corrigir apenas os danos raciais extremamente gritantes, aqueles que todos notariam e condenariam.** Mas se o racismo está enraizado em nossos processos de pensamento e estruturas sociais tão profundamente quanto muitos crits acreditam, então os "assuntos cotidianos" da sociedade – as rotinas, práticas e instituições com as quais contamos para fazer o mundo funcionar – manterão as minorias em posições subordinadas. Somente esforços agressivos e conscientes que levem em conta as minorias poderão mudar a maneira como as coisas são no sentido de amenizar a miséria. Como exemplo de uma dessas estratégias, um acadêmico da teoria crítica da raça propôs que a sociedade "olhe para baixo" ao analisar novas leis. Caso não aliviem o sofrimento do grupo mais pobre – ou, pior ainda, o agravem –, deveríamos rejeitá-las. Embora a neutralidade racial pareça estar firmemente arraigada no Judiciário, alguns juízes abriram exceções em circunstâncias incomuns.

➥ Delgado, Richard; Stefancic, Jean. Teoria Crítica da Raça: uma introdução. Editora Contracorrente. Edição do Kindle.

☑ **(Defensor DPESP 2023 FCC correta)** Segundo Delgado e Stefancic, em seu livro "Teoria Crítica da Raça", uma crítica que os teóricos da teoria crítica da raça endereçam à neutralidade racial consiste em afirmar que ela nos permitirá corrigir apenas os danos raciais extremamente gritantes.

Convenção Interamericana contra o Racismo (Decreto 10.932/2022)	**Material disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório** https://www.proleges.com.br/
• Internalizada na ordem jurídica brasileira com **status de emenda constitucional** (art. 5º, § 3º, CF/88). • Prevê definições sobre: discriminação racial, discriminação racial indireta, discriminação múltipla ou agravada, racismo, intolerância.	

Lei do Crime Racial (Lei 7.716/1989)	**Material disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório** https://www.proleges.com.br/
• Novidade do material: atualizado com a Lei 14.532/2023, a qual equiparou a injúria racial ao crime de racismo entre outras mudanças.	

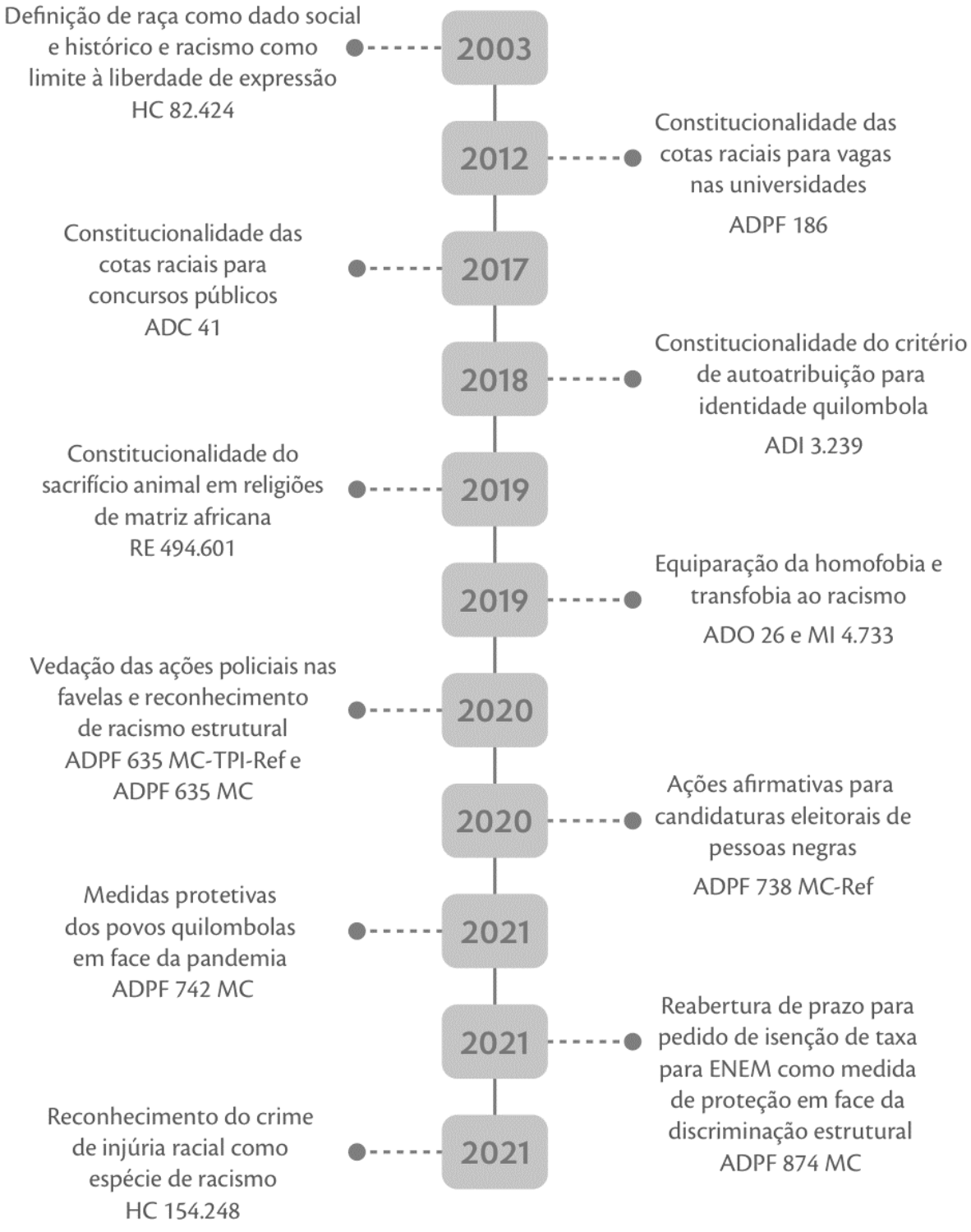
Comentários da Lei 14.532/2023	**Material disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório** https://www.proleges.com.br/
• Material específico sobre a Lei 14.532/2023, a qual equiparou a injúria racial ao crime de racismo entre outras mudanças.	

Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010)	**Material disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório** https://www.proleges.com.br/
• Estatuto da Igualdade Racial comentado e grifado.	

O que é necropolítica?	
• O conteúdo está disponível no nosso material de Criminologia.	**Material disponível na pasta de Criminologia** https://www.proleges.com.br/ 

Clique aqui para voltar ao SUMÁRIO

DIREITO À IGUALDADE RACIAL



Jurisprudência do STF
• Definição de raça como dado social e histórico e racismo como limite à liberdade de expressão (HC 82.424 – Caso Ellwanger). **[1]** • Constitucionalidade das cotas raciais para vagas nas universidades (ADPF 186). **[2]** • Constitucionalidade das cotas raciais para concursos públicos (ADC 41). **[3]** • Constitucionalidade do critério de autoatribuição para identidade quilombola (ADI 3.239). **[4]** • Constitucionalidade do sacrifício animal em religiões de matriz africana (RE 494.601). **[5]** • Equiparação da homofobia e transfobia ao racismo (ADO 26 e MI 4.733). **[6]**

- Vedação das ações policiais nas favelas e reconhecimento de racismo estrutural (ADPF 635 MC-TPI-Ref e ADPF 635 MC). **[7]**
- Ações afirmativas para candidaturas eleitorais de pessoas negras (ADPF 738 MC-Ref). **[8]**
- Medidas protetivas dos povos quilombolas em face da pandemia (ADPF 742 MC). **[9]**
- Reabertura de prazo para pedido de isenção de taxa para ENEM como medida de proteção em face da discriminação estrutural (ADPF 874 MC). **[10]**
- Reconhecimento do crime de injúria racial como espécie de racismo (HC 154.248). **[11]**

[1] HC 82.424: caso Ellwanger – conceito de racismo e alcance da liberdade de expressão. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Siegfried Ellwanger, para afastar a aplicação do tipo penal de racismo às publicações preconceituosas contra o povo judeu. O STF, por maioria, denegou a ordem, condenando a discriminação a grupos sociais historicamente racializados, em prejuízo ao direito à liberdade de expressão do paciente, endossando que o discurso discriminatório não é protegido pelo direito à liberdade de expressão.

[2] ADPF 186: ações afirmativas étnico-raciais para ingresso em universidades públicas. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental que visa à declaração de inconstitucionalidade de atos da Universidade de Brasília – UnB, os quais instituíram o sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial (20% de cotas étnico-raciais) no processo de seleção para ingresso de estudantes. O STF julgou improcedente a ação, reconhecendo a validade dos atos, em respeito ao princípio da igualdade material.

[3] ADC 41: reserva de vagas para negras e negros em concursos públicos. Trata-se de ação declaratória de constitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo por objeto a Lei n° 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. O STF afirmou a constitucionalidade da lei, destacando, dentre outros argumentos, o respeito ao princípio da igualdade material.

[4] ADI 3.239: critério de autoatribuição para identificação de comunidades quilombolas. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Decreto n. 4887, julgada improcedente por maioria, para reconhecer como constitucional o critério de autoatribuição da identidade de quilombola previsto no Decreto n. 4887/2003 para a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de suas terras prevista no artigo 68 do ADCT. A decisão invocou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, internalizada ao direito brasileiro, bem como a não exclusividade de tal critério, dado que sujeito a controles institucionais.

[5] RE 494.601: discriminação de religiões de matriz africana e sacrifício animal. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta contra lei estadual que autorizou o sacrifício de animais no caso de rituais em cultos e liturgias de matriz africana. Foi julgada improcedente pela maioria do STF, declarando constitucional a lei. O STF salientou a proteção constitucional conferida à liberdade de religião e aos direitos culturais de grupos minoritários, ressaltando a condição de especial vulnerabilidade de seus praticantes, quer por se tratar de crença extremamente minoritária, quer por ser comumente alvo de discriminação e de violência de cunho racial.

[6] ADO 26: criminalização da homotransfobia e o racismo em sua dimensão social. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão proposta pelo Partido Popular Socialista – PPS, em face de alegada inércia legislativa atribuída ao Congresso Nacional, que estaria frustrando a tramitação e a apreciação de proposições legislativas apresentadas com o objetivo de incriminar todas as formas de homofobia e de transfobia. A decisão conferiu interpretação conforme à Constituição, entendendo que as práticas homofóbicas e transfóbicas se enquadram no crime de racismo e configuram atos delituosos passíveis de repressão penal, por efeito de mandados constitucionais de criminalização (CF, art. 5º, incisos XLI e XLII), dado que traduzem expressões de racismo em sua dimensão social. • **MI 4.733: criminalização da homotransfobia e o racismo em sua dimensão social.** Trata-se de mandado de injunção que visa ao reconhecimento da mora do Congresso Nacional na elaboração de lei para criminalizar as práticas discriminatórias contra pessoas LGBTQIA+ (homofobia, transfobia). Foi julgado procedente para estender ao caso a aplicação da Lei 7.716/89 (que trata do combate ao racismo) até que a lei em questão seja criada.

Invocou-se, no caso, o direito à igualdade, a vedação constitucional a qualquer tipo de discriminação ilegítima, bem como dispositivo constitucional que reconhece outros direitos previstos em tratado de que o Brasil é parte (art. 5º, § 2º, CF).

[7] ADPF 635 MC-TPI-Ref: vedação das ações policiais nas favelas durante a pandemia. Trata-se de medida incidental em medida cautelar na ADPF 635, deferida para o fim de determinar que não fossem realizadas operações policiais nas favelas no Rio de Janeiro durante a pandemia de covid-19, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, dando cumprimento à sentença interamericana proferida no caso Favela Nova Brasília, a fim de resguardar o direito à vida, à integridade física e à segurança dos moradores, considerando ainda o impacto desproporcional sobre a população negra ou parda de tais comunidades. • **ADPF 635 MC: vedações das ações policiais nas favelas durante a pandemia.** Trata-se de medida cautelar em ADPF, deferida para determinar medidas de controle à violência e à letalidade policial no Rio de Janeiro, a qual tem um viés que atinge desproporcionalmente a população negra ou parda. A ação foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a omissão estrutural dos poderes públicos na proteção dos direitos humanos fundamentais da população atingida, em virtude da falta de investigação e punição de medidas policiais desproporcionais e discriminatórias.

[8] ADPF 738 MC-Ref: candidaturas eleitorais de negros e pardos a cargos políticos. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), a fim de que o STF determine a imediata aplicação dos efeitos do julgamento proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, concernente à interpretação que promove incentivo às candidaturas de pessoas negras para cargos eletivos, em atenção ao princípio da igualdade, considerando que a medida não interfere sobre o princípio da anterioridade eleitoral.

[9] ADPF 742 MC: proteção das comunidades quilombolas em face da Covid-19. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, tendo por objeto atos comissivos e omissivos do Poder Executivo federal quanto ao enfrentamento da pandemia covid-19 nas comunidades quilombolas. O STF entendeu ser dever do Poder Público elaborar e implementar plano para enfrentar a pandemia consideradas as particularidades das comunidades quilombolas, instituindo grupo de trabalho interdisciplinar e paritário, com o objetivo de inclusão, nos registros de covid-19, do quesito raça/cor/etnia, asseguradas notificação dos casos confirmados e ampla e periódica publicidade. Determinou, ainda, suspensão da tramitação de demandas judiciais envolvendo direitos territoriais, a exemplo de ações possessórias, reivindicatórias de propriedade, imissões na posse e anulatórias de demarcação.

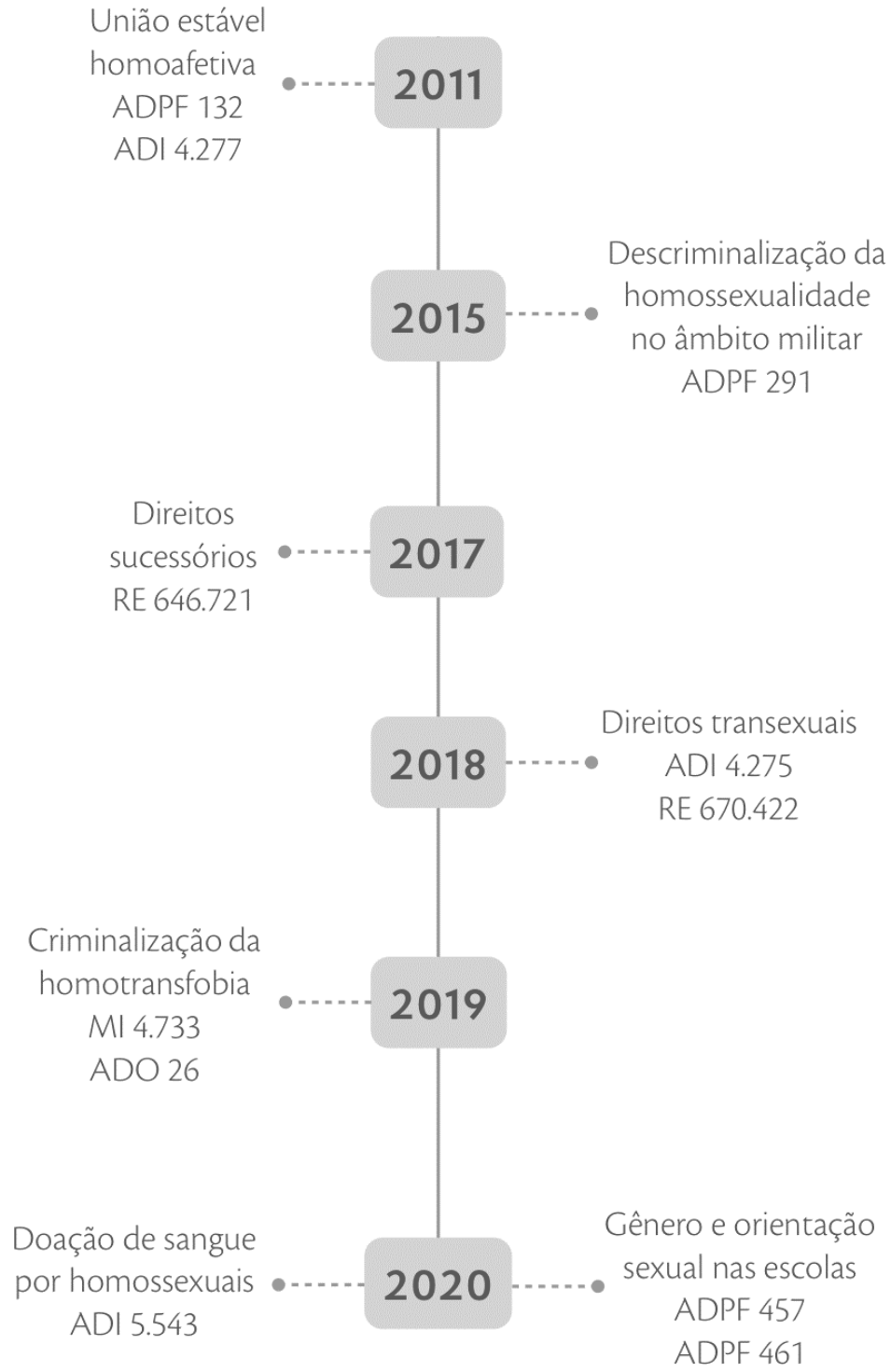
[10] ADPF 874 MC: direito à educação e racismo. Trata-se de medida cautelar deferida pelo STF, em sede de arguição de des- cumprimento de preceito fundamental, para determinar a reabertura do prazo de requerimento de isenção de pagamento de taxa para inscrição no ENEM 2021, com fundamento no direito à educação, inclusão social e a promoção da diversidade no ensino superior, bem como a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino.

[11] HC nº 154.248: injúria racial como espécie do gênero racismo. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, denegado pelo STF, por maioria de votos, a fim de reconhecer que o tipo penal da injúria racial é uma espécie do gênero racismo, configurando crime imprescritível.

Caderno de jurisprudência do STF: Direito à Igualdade Racial	**Material disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório** https://www.proleges.com.br/ 
• Cada julgado retromencionado da Jurisprudência do STF está sistematizado neste material gratuito. • Vale conferir o material (publicado em mar/2023).	

Clique aqui para voltar ao SUMÁRIO

DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIAP+



Jurisprudência do STF
• União estável homoafetiva (ADPF 132; ADI 4.277). **[1]** • Descriminalização da homossexualidade no âmbito militar (ADPF 291). **[2]** • Direitos sucessórios: equiparação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros em união estável homoafetiva (RE 646.721). **[3]** • Alteração do nome e adequação de gênero em cartório extrajudicial (ADI 4.275). **[4]** • Direitos transexuais: alteração do nome e sexo no registro civil de pessoas transexuais mesmo sem intervenção cirúrgica (RE 670.422). **[5]**

- Homofobia e transfobia configuram racismo (ADO 26 e MI 4.733). **[6]**
- Gênero e orientação sexual nas escolas (ADPF 457; ADPF 461). **[7]**
- É inconstitucional a proibição de doação de sangue por homens homossexuais (ADI 5.543). **[8]**

[1] ADPF 132 e ADI 4.277: união estável homoafetiva. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF nº 132) que tem como objeto a interpretação conforme dos arts. 19, II e V, e 33 do Decreto-Lei nº 220/1975 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro); e de ação direta de inconstitucionalidade (ADI nº 4277), com pedido de interpretação conforme à Constituição do art. 1.723 do Código Civil (CC). O Supremo Tribunal Federal recebeu a ADPF como ADI e julgou procedentes ambas as ações, para o fim de excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, atribuindo-lhe, ainda, as mesmas regras e consequências jurídicas inerentes à união estável heterossexual.

[2] ADPF 291: crime de pederastia ou outro ato de libidinagem no âmbito militar. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental que tem como objeto o art. 235 do Código Penal Militar. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação e declarou não recepcionados pela Constituição Federal os termos "pederastia ou outro", bem como a expressão "homossexual ou não", constante do caput do dispositivo, por conflitarem com o direito à liberdade de orientação sexual.

[3] RE 646.721: equiparação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros em união estável homoafetiva. Trata-se de recurso extraordinário que tem por objeto a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, à luz dos arts. 1º, III, 5º, I, e 226, §3º, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso e declarou o direito do recorrente à herança de seu companheiro, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da proporcionalidade, da vedação do retrocesso, assim como tendo em vista a não hierarquização entre entidades familiares.

[4] ADI 4.275: alteração do nome e sexo de pessoas transexuais no registro civil. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 58 da Lei nº 6.015/1973. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação e atribuiu ao dispositivo interpretação conforme à Constituição e ao Pacto de São José da Costa Rica, à luz dos direitos à dignidade, à honra e à liberdade, entre outros, para reconhecer aos transgêneros o direito à substituição de prenome e sexo no registro civil, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes.

[5] RE 670.422: alteração do nome e sexo no registro civil de pessoas transexuais mesmo sem intervenção cirúrgica. Trata-se de recurso extraordinário que tem por objeto a inconstitucionalidade dos arts. 55, parágrafo único, 56 a 58, caput e seu parágrafo único, da Lei 6.015/1973, Lei dos Registros Públicos (LRP), à luz dos arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, X; e 6º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso para reconhecer às pessoas transgêneras o direito subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, independentemente de procedimento cirúrgico de redesignação. Determinou a averbação da informação à margem no assento de nascimento, vedada a inclusão do termo "transexual".

[6] MI 4.733. Trata-se de mandado de injunção, cujo objeto é a omissão do Congresso Nacional quanto ao seu dever de criminalização de condutas ofensivas, ameaçadoras e discriminatórias, em razão da orientação sexual e/ou identidade de gênero. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação para: (i) reconhecer a mora inconstitucional do Legislativo e (ii) determinar, com efeitos prospectivos, a aplicação da tipificação constante da Lei 7.716/1989, pertinente aos crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, à discriminação por orientação sexual e/ou identidade de gênero, até que se venha legislar a respeito. • **ADO 26.** Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão que tem por objeto a omissão do Congresso Nacional na criminalização de condutas homotransfóbicas. O Supremo Tribunal Federal conheceu parcialmente da ação e, em tal extensão, julgou procedente o pedido para afirmar a inconstitucionalidade por omissão e determinar que, até que sobrevenha norma a respeito, deve-se aplicar a condutas homotransfóbicas a Lei 7.716/1989, que tipifica os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

[7] ADPF 457: divulgação de material escolar sobre gênero e orientação sexual. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental que tem como objeto a análise da constitucionalidade da Lei 1.516/2015 do Município de Novo Gama (GO), que proibiu a divulgação de material sobre "ideologia de

gênero" nas escolas. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado na ação, para declarar a inconstitucionalidade, formal e material, da referida legislação, por usurpação da competência privativa da União para legislar a respeito de diretrizes e bases da educação, do princípio da liberdade de aprender e de ensinar, e do dever estatal de combate à discriminação por orientação sexual e de gênero, entre outros. • **ADPF 461: ensino sobre gênero e orientação sexual nas escolas.** Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental que tem como objeto a análise do art. 3º, X, parte final, da Lei 3.468/2015 do Município de Paranaguá (PR), que que veda o ensino sobre gênero e orientação sexual. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado na ação, para declarar a inconstitucionalidade, formal e material, do dispositivo em questão, uma vez que a norma compromete o acesso de crianças, adolescentes e jovens a conteúdos relevantes, pertinentes à sua vida íntima e social, em desrespeito à doutrina da proteção integral.

[8] ADI 5.543: doação de sangue por homossexuais. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 64, IV, da Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde, e o art. 25, XXX, "d", da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (RDC nº 34/2014 da ANVISA). O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação para declarar inconstitucionais os referidos dispositivos, por configurarem indevida discriminação por orientação sexual e ofenderem a dignidade da pessoa humana e o direito à igualdade.

Caderno de jurisprudência do STF: Direito das Pessoas LGBTQIAP+	**Material disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório** https://www.proleges.com.br/ 
• Cada julgado retromencionado da Jurisprudência do STF está sistematizado neste material gratuito. • Vale conferir o material (publicado em mar/2023).	

CNJ
• Provimento 73/2018 (CNJ): mudança de nome por pessoa trans. • Resolução 270/2018 (CNJ): dispõe sobre o uso do nome social pelas pessoas trans, travestis e transexuais usuárias dos serviços judiciários, membros, servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados dos tribunais brasileiros. • Resolução 348/2020 (CNJ): estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente.

Jurisprudência do STJ
• A Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica (REsp 1977124/SP). • É possível a adoção de uma criança por casal homoafetivo (REsp 1281093/SP).

OC 24/2017: identidade de gênero, igualdade e não discriminação a casais do mesmo sexo (Corte IDH)

• Para a Corte IDH (Opinião Consultiva 24/2017), é possível a mudança de nome, a adequação da imagem e a retificação do sexo ou gênero nos registros e nos documentos de identidade (de acordo com a identidade de gênero autopercebida). Direito esse protegido pelos artigos 18 (direito ao nome), 13 (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 7.1 (direito à liberdade), 11.2 (direito à vida privada) da CADH. Logo, os Estados estão obrigados a reconhecer, regular e estabelecer os procedimentos adequados para tais fins.

• O STF está alinhado com o posicionamento da Corte IDH (ADI 4.275).

> **Transgênero pode alterar seu prenome e gênero no registro civil mesmo sem fazer cirurgia de transgenitalização e mesmo sem autorização judicial**
>
> O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa.
>
> Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo "transgênero".
>
> Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial.
>
> Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos.
>
> STF. Plenário. RE 670422/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/8/2018 (repercussão geral) (Info 911).
>
> Os transgêneros, que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, possuem o direito à alteração do prenome e do gênero (sexo) diretamente no registro civil.
>
> O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero.
>
> A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la.
>
> A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade.
>
> STF. Plenário. ADI 4275/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 28/2 e 1º/3/2018 (Info 892).
>
> Para mais informações de como isso se efetua na prática, consulte o Provimento n. 73/2018, do CNJ, que dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN).
>
> ➥ Buscador Dizer o Direito: https://bit.ly/3nLfr3y.

• Provimento 73/2018 (CNJ): mudança de nome por pessoa transgênero.

• Resolução 270/2018 (CNJ): dispõe sobre o uso do nome social pelas pessoas trans, travestis e transexuais usuárias dos serviços judiciários, membros, servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados dos tribunais brasileiros.

• Resolução 348/2020 (CNJ): estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente.

Corte IDH
(Corte Interamericana de Direitos Humanos)

CASO ATALA RIFFO VS. CHILE



• Temas principais: **i)** guarda das crianças e a orientação sexual dos pais; **ii)** conceito de família e a CADH (Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Decreto 678/1992).
• O caso versa sobre responsabilidade internacional do Estado pelo **tratamento discriminatório e interferência arbitrária na vida privada e familiar de Karen Atala Riffo**.
☑ **(Defensor DPESP 2013 FCC correta)** No caso Atala Riffo y ninãs, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu pela responsabilidade internacional do Estado violador em face do tratamento discriminatório e da interferência indevida na vida privada da vítima em razão de sua orientação sexual.
• Karen Atala Riffo encerrou seu casamento com Ricardo Jaime, com o qual tinha três filhas, que ficariam aos cuidados de Karen Atala Riffo.
• Em seguida, Emma de Ramón (na imagem: à direita), companheira de Karen Atala Riffo (na imagem: à esquerda), começou a conviver na mesma casa com Karen e as filhas.
• Ricardo Jaime ajuizou ação, requerendo a guarda das filhas, afirmando que a orientação sexual poderia expor/prejudicar as filhas a discriminação e causar confusão psicológica, segundo o "modelo tradicional" de família normalmente apreciada no meio social. O caso se estendeu por todo o Judiciário chileno até chegar a Corte Suprema de Justiça do Chile (que acolheu o pedido de Ricardo Jaime: destituição da guarda).
• O caso chegou na Corte IDH.
• **Primeiro precedente da Corte IDH a respeito do direito à diversidade sexual**.
☑ **(Defensor DPESP 2015 FCC correta)** No caso Atala Riffo, a Corte Interamericana afirmou, pela primeira vez, que orientação sexual e identidade de gênero são categorias protegidas pela Convenção Americana de Direitos Humanos, após considerar discriminatória decisão da Suprema Corte do Chile que retirou da mãe a guarda das filhas em virtude de convivência homoafetiva.
• A Corte IDH entendeu que **a orientação sexual dos pais das crianças não pode ser fundamento para decidir processo judicial de guarda**.
• O **superior interesse da criança não pode ser utilizado para amparar discriminação contra os pais** em razão de sua orientação sexual.
☑ **(Defensor DPEMS 2022 FGV correta)** Atala Riffo e crianças vs. Chile, em que a Corte IDH afirmou que o interesse superior da criança não pode ser utilizado para amparar discriminação contra os pais em razão de sua orientação sexual.
• Logo, **não se acolheu a tese de modelo tradicional de família**, pois o conceito de vida familiar não está restrito unicamente ao matrimônio.

Princípios de Yogyakarta

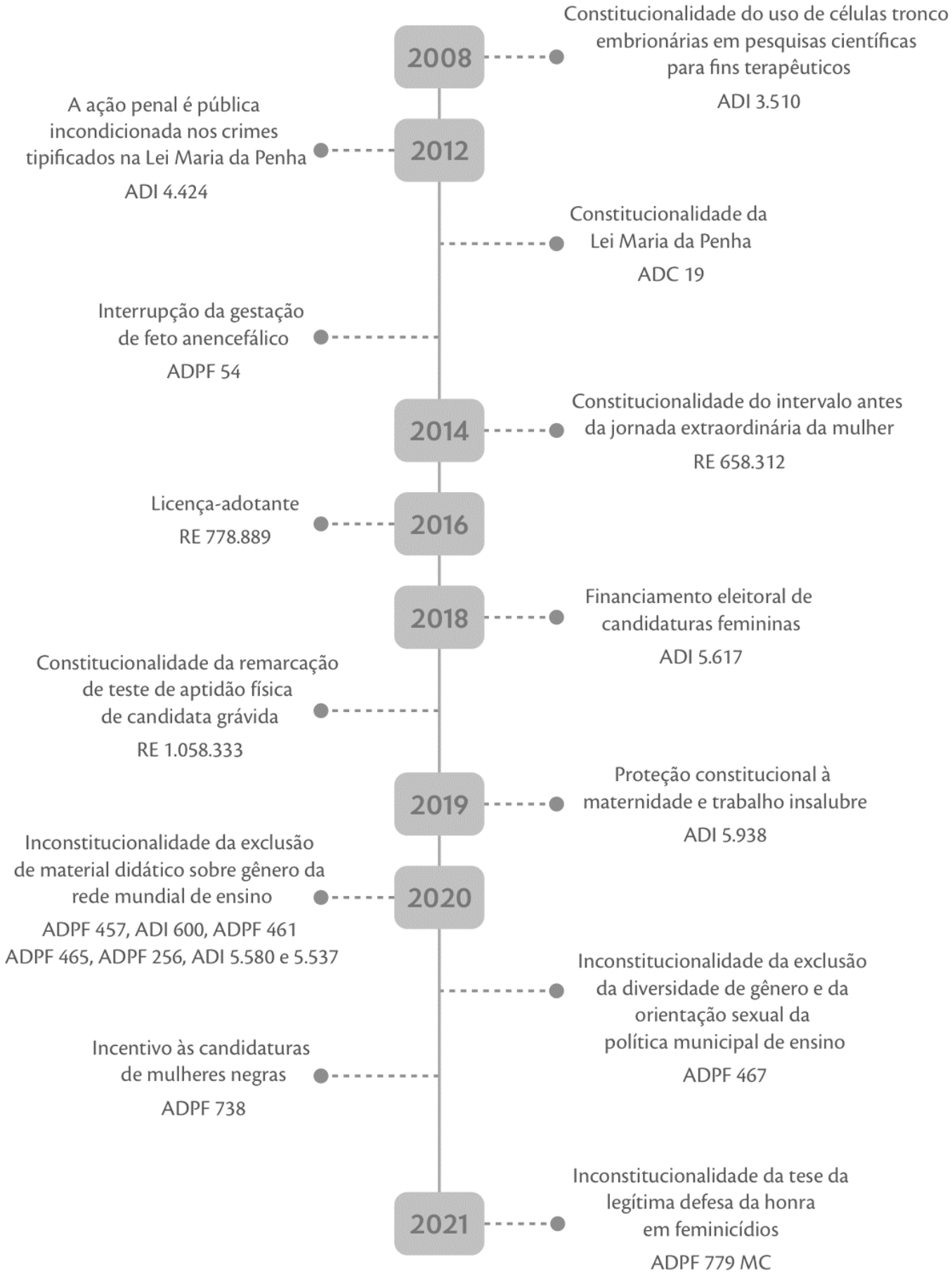
• É norma *soft law* (não vinculante), pois não se trata de tratado internacional de direitos humanos.

Material disponível
na pasta de
Direito Antidiscriminatório
https://www.proleges.com.br/



Clique aqui para voltar ao SUMÁRIO

DIREITOS DAS MULHERES



Jurisprudência do STF
• Lei de biossegurança – pesquisas com células tronco embrionárias (ADI 3.510). **[1]** • A ação penal é pública incondicionada nos crimes tipificados na Lei Maria da Penha (ADI 4.424). **[2]** • Constitucionalidade da Lei Maria da Penha (ADC 19). **[3]** • Interrupção da gestação de feto anencefálico (ADPF 54). **[4]** • Constitucionalidade do intervalo antes da jornada extraordinária da mulher (RE 658.312). **[5]** • Licença-adotante (RE 778.889). **[6]** • Financiamento eleitoral de candidaturas femininas (ADI 5.617). **[7]** • Constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física de candidata grávida (RE 1.058.333).**[8]** • Proteção constitucional à maternidade e trabalho insalubre (ADI 5.938). **[9]** • Inconstitucionalidade da exclusão de material didático sobre gênero da rede mundial de ensino (ADPF 457, ADI 600, ADPF 461 ADPF 465, ADPF 256, ADI 5.580 e 5.537). **[10]** • Inconstitucionalidade da exclusão da diversidade de gênero e da orientação sexual da política municipal de ensino (ADPF 467). **[11]** • Incentivo às candidaturas de mulheres negras (ADPF 738). **[12]** • Inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra em feminicídios (ADPF 779 MC). **[13]**

[1] ADI 3.510: Lei de biossegurança – pesquisas com células tronco embrionárias. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto o artigo 5º da Lei Federal no 11.105 (“Lei de Biossegurança”), de 24 de março de 2005, que dispôs sobre a pesquisa com células tronco embrionárias. Alegou-se que a utilização de embriões humanos para tais fins implicaria sua destruição, violando seu direito à vida. A ação foi julgada improcedente, por maioria dos votos, por se entender que o embrião pré-implantado é um bem a ser protegido, mas não uma pessoa no sen- tido a que se refere a Constituição. A decisão enfatiza que a Lei de Biossegurança não veicula autorização para extirpar do corpo feminino esse ou aquele embrião. Não se cuida de interromper a gravidez humana, mas de embrião resultante de procedimento de fertilização in vitro, a ser descartado. Destacou-se, ainda, o direito à autonomia da vontade, ao planejamento familiar e à maternidade, no sentido de que o recurso a processos de fertilização artificial não implica o dever da tentativa de nidação no corpo da mulher de todos os óvulos afinal fecundados.

[2] ADI 4.424: violência doméstica – ação penal pública incondicionada. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto a Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95). Postula-se que lhe seja dada interpretação conforme, com base nos artigos 5º, inciso XLI, e 226, § 8º, da Constituição de 1988, a fim de que a referida norma não seja aplicada aos crimes tipificados na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) e aos crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no ambiente doméstico, declarando-se, portanto, a necessidade de ação penal pública incondicionada.

[3] ADC nº 19: violência doméstica – constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Trata-se de ação declaratória de constitucionalidade, tendo por objeto os artigos 1º, 33 e 41 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), julgados inconstitucionais por vários tribunais por ofender os princípios da igualdade e da proporcionalidade. Pleiteia-se o reconhecimento da consonância dos artigos da norma mencionada com o Preâmbulo da Constituição de 1988 e com os artigos 3º, inciso III, 5º, caput e inciso I, 7º, incisos XXX, XXXI, XXXII e XXXIV, 14, caput, 37, inciso XXI, 150 inciso II, 170, inciso VII, 206, inciso I, e 226, § 5º, da Constituição de 1988.

[4] ADPF 54: interrupção da gestação de feto anencefálico. Trata-se de ação de descumprimento de preceito fundamental, tendo por objeto a interrupção de gestação em caso de feto anencefálico e sua caracterização como aborto criminoso. O STF julgou o pedido procedente, por maioria, declarando inconstitucional a interpretação segundo a qual a interrupção de gravidez de fetos anencéfalos é equivalente às condutas penais relacionadas ao crime de aborto.

[5] RE 658.312: intervalo antes da jornada extraordinária da mulher. Trata-se de recurso extraordinário que discutiu a constitucionalidade do intervalo de 15 minutos para mulheres trabalhadoras antes da jornada extraordinária. O STF, por maioria de votos, negou provimento ao recurso com a fixação das teses jurídicas de que o art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e de que a norma se aplica a todas as mulheres trabalhadoras.

[6] RE 778.889: licença-adotante. Trata-se de recurso extraordinário em que se alega a incompatibilidade da dis- tinção de tratamento entre a licença gestante e a licença adotante com a licença maternidade prevista pelo art. 7º, XVIII da Constituição. A decisão assentou a necessidade de uma interpretação sistemática do texto constitucional à luz da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre filhos biológicos e adotados, da autonomia da mulher e do princípio do melhor interesse da criança. Reforçou-se o dever do Estado de oferecer condições que compatibilizem a maternidade e a profissão, sobretudo, quando a primeira é exercida a partir da adoção, sendo necessária atenção à adaptação do adotado. Nesse sentido, foram declarados inconstitucionais o art. 210 da Lei nº 8.112/1990 e os parágrafos 1º e 2º do art. 3º da Resolução CJF nº 30/2008, que fixavam a licença maternidade destinada à adotante em tempo inferior à licença-gestante. Assim, o recurso extraordinário foi provido de modo a deferir à recorrente prazo remanescente de licença parental e foi firmada tese de repercussão geral que equipara os prazos da licença adotante e de suas prorrogações aos prazos da licença gestante, independentemente da idade da criança adotada.

[7] ADI 5.617: financiamento eleitoral de candidaturas femininas. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que impugnou o disposto no art. 9º da Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015. O dispositivo alterou diversas normas eleitorais com o objetivo, expresso no próprio texto legal, de "reduzir os custos das campanhas eleitorais, simplificar a administração dos Partidos Políticos e incentivar a participação feminina". Por maioria e nos termos do voto do relator, a ação direta foi julgada procedente para: i) declarar a inconstitucionalidade da expressão "três", contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido, para as eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja alocado na mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/1995.

[8] RE 1.058.333: igualdade material, liberdade individual, direito à saúde, à maternidade e ao planejamento familiar. Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Estado do Paraná, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve sentença que admitiu a realização de segunda chamada de teste de aptidão física em concurso público, devido à impossibilidade de participação de candidata grávida na data inicialmente fixada. A decisão considerou que, em atenção ao princípio da isonomia, a candidata só poderia demonstrar sua aptidão física após superado o estado gravídico e que a realização do teste em período de gestação colocaria em risco a saúde da mãe e do bebê. Ademais, seria uma forma de assegurar os direitos à maternidade e ao planejamento familiar consagrados pelo texto constitucional. Desse modo, foi reconhecida a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física de candidata grávida aprovada nas provas escritas, independentemente de previsão expressa em edital, e fixada tese de repercussão geral.

[9] ADI 5.938: proteção constitucional à maternidade e trabalho insalubre. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em que se objetiva a declaração da inconstitucionalidade da expressão "quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento", contida nos incisos II e III do art. 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inseridos pelo art. 1o da Lei 13.467/2017. A ação foi julgada procedente, por maioria dos votos, sob o fundamento de que a proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico, de forma a evitar sua submissão a trabalho insalubre. Entendimento diverso prejudicaria a mãe e o recém-nascido.

[10] ADPF 457, ADI 600, ADPF 461 ADPF 465, ADPF 256, ADI 5.580 e 5.537: exclusão de material didático sobre gênero da rede municipal de ensino. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, para questionar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.516/2015 do Município de Novo Gama – GO, que proibiu a utilização em escolas públicas municipais de material didático que contivesse ideologia de gênero.

[11] ADPF 467: exclusão da diversidade de gênero e da orientação sexual da Política Municipal de Ensino. Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, contra os artigos 2º, caput, e 3º, caput, da Lei n. 3.491, de 28 de agosto de 2015, do Município de Ipatinga (MG), que excluem da política municipal de ensino qualquer referência à diversidade de gênero e orientação sexual. Na decisão, para além do vício formal, no que se refere à competência para edição de normas gerais sobre educação, reconheceu-se que as referidas normas acabariam por cristalizar uma cosmovisão tradicional de gênero e sexualidade que ignora o pluralismo da sociedade moderna. Entendeu-se que a legislação impugnada contraria não só normas de status constitucional, como também normas internacionais que proíbem qualquer tipo de discriminação.

[12] ADPF 738: candidaturas de mulheres negras. Trata-se de ação de descumprimento de preceito fundamental, em que se pleiteou o reconhecimento e a imediata aplicação dos efeitos do julgamento realizado pelo TSE, na Consulta nº 0600306-47.2019.6.00.0000, que definiu medidas de incentivo às candidaturas de pessoas negras a serem observadas a partir das eleições de 2022. A análise do STF considerou a necessidade de implantação de políticas públicas de caráter afirmativo, a fim de concretizar a dimensão material do princípio da igualdade, previsto pelo art. 5º, caput, da Constituição. Ademais, firmou-se o entendimento de que a decisão do TSE não constituía ofensa ao princípio da anterioridade, pois não introduzia qualquer inovação nas normas relativas ao processo eleitoral, apenas as aperfeiçoava com intuito de ampliar a participação política de cidadãos negros. Assim, foi deferida a medida cautelar e referendada pelo Plenário, para a aplicação dos incentivos às candidaturas de pessoas negras, em conformidade com a resposta do TSE à Consulta 600306-47, ainda nas eleições de 2020.

[13] ADPF MC 779: legítima defesa da honra e igualdade de gênero. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, na qual se objetivou o afastamento da tese jurídica da legítima defesa da honra, com base em interpretação conforme à Constituição dos artigos 23, inciso II, e 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e do artigo 65 do Código de Processo Penal. Na decisão, avaliou-se que a "legitima defesa da honra" não consiste tecnicamente em uma legítima defesa, porém é frequentemente utilizada para justificar ataques desproporcionais, covardes e criminosos a mulheres. Nessa toada, entendeu-se que a tese viola a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à igualdade entre homens e mulheres e contribui para a naturalização e perpetuação da violência contra a mulher. Diante disso, concedeu-se parcialmente a medida cautelar.

Corte IDH
(Corte Interamericana de Direitos Humanos)

CASO GONZÁLEZ E OUTRAS (CAMPO ALGODOEIRO) VS. MÉXICO

• **Primeira vez que a Corte IDH analisou um caso sobre situação de violência estrutural de gênero.**

#Atenção Não confundir: o Caso do Presídio Miguel Castro Castro foi o primeiro precedente da Corte IDH sobre violência de gênero.

> No caso que ora nos ocupa, o grande diferencial entre ambas ocasiões se encontra na natureza das **violações contra a mulher** – as quais ocorreram, no caso ora analisado, **de forma estrutural**, até porque os desaparecimentos ocorreram de modo e em períodos diferentes –, bem como na controvérsia, por parte do Estado, em relação à competência da Corte para aplicar diretamente disposições da Convenção de Belém do Pará, o que não havia ocorrido anteriormente (§ 76).
>
> Nesse sentido, apesar de não ser objeto da análise de mérito, considera-se importante indicar que **o caso que ora nos ocupa foi o primeiro, em toda a jurisprudência da Corte, em que o tribunal esclareceu sua competência para determinar a violação, de forma direta, do art. 7º da Convenção de Belém do Pará**, a qual já havia sido aplicada em 2006 (caso Presídio Miguel Castro Castro vs. Peru) e em 2009 (caso Ríos e outros vs. Venezuela e Perozo vs. Venezuela), o que, segundo a Corte, era equivalente a declarar sua competência sobre o dispositivo.
>
> (...)
>
> A violência estrutural de gênero contra a mulher tem por característica a transgressão de direitos relacionados ao tema de forma coletiva, frequente e em momentos diferentes. Além disso, nesse

> contexto a impunidade dos agressores é padrão, o que corrobora a perpetuação da prática violadora.
> MAZZUOLI, Valerio. Direitos humanos na jurisprudência internacional. Grupo GEN, 2022, p. 548/549.

• **Primeira vez que um tribunal internacional reconhece o "feminicídio" como crime.** Lembrando que o Código Penal brasileiro passou a prever o feminicídio com a Lei 13.104/2015, o qual ingressou no ordenamento jurídico como *qualificadora* do crime de homicídio (art. 121, § 2º, do CP).

• **Resumo do caso:** "Narra a demanda que, no ano de 2001, diversas jovens haviam desaparecido na cidade de Juarez, em ocasiões diferentes. Apesar de seus familiares terem denunciado diversas vezes, o Estava havia se mantido omisso em seu dever de investigar. No final do mesmo ano, os corpos de três das vítimas foram encontrados, apresentando sinais de violência sexual, de modo a demonstrar que as mesmas haviam sido mantidas em cárcere privado antes de serem assassinadas." – ensina Mazzuoli (2022, p. 546).

• **Principais pontos do caso:**

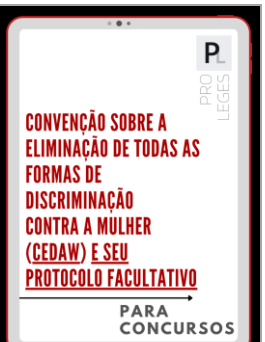
i) Violência estrutural de gênero;

ii) Competência da Corte IDH para aplicar o art. 7º da Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher) diretamente aos casos que são submetidos à sua apreciação;

iii) Primeira vez que um tribunal internacional reconhece o "feminicídio" como crime.

➥ Conferir as **Regras de Bangkok** na pasta de Direitos Humanos.

Caderno de jurisprudência do STF: Direitos das Mulheres	**Material disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório** https://www.proleges.com.br/
• Cada julgado retromencionado da Jurisprudência do STF está sistematizado neste material gratuito. • Vale conferir o material (publicado em mar/2023).	

CEDAW (Decreto 4.377/2002) e seu Protocolo Facultativo	**Material disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório** https://www.proleges.com.br/
• Comentamos e está disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório.	

Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006)	Material disponível na pasta de Leis Penais Especiais https://www.proleges.com.br/	
• Comentamos a Lei Maria da Penha e está disponível na pasta de Leis Penais Especiais.		

Clique aqui para voltar ao SUMÁRIO

DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

2009

- Regime constitucional de demarcação de terras indígenas (Caso Raposa Serra do Sol)

  Pet 3.388

2013

- Regime constitucional para a proteção de terras indígenas e efeitos limitados ao caso (Caso Raposa Serra do Sol)

  Pet 3.388 ED

2017

- Tutela do direito dos povos quilombolas à terra e impossibilidade de sua outorga a terceiros

  ADI 4.269

2018

- Constitucionalidade do Decreto 4.887/2003, que regulamentou a demarcação de territórios quilombolas

  ADI 3.239

2019

- Regime jurídico constitucional aplicável às relações de posse indígena e à demarcação de suas terras

  RE 1.017.365 RG

- Acesso à justiça e exigência de coerência funcional aos órgãos que garantem a proteção dos direitos de povos tradicionais

  ADI 6.062 MC-Ref

- Direito à consulta livre, prévia e informada

  SL 995 AgR

2020

- Imprescritibilidade de pretensão de reparação civil de dano ambiental (Comunidade Ashaninka-Kampa do Rio Amônia)

  RE 654.833

- Direito à propriedade coletiva comunal – indeferimento de pagamento de indenização por expropriação de propriedades reconhecidas como de ocupação tradicional (Reserva Indígena Ibirama-La Klanó)

  SL 610 AgR-2ºjulg

- Descabimento de mandado de segurança para debater a posse indígena e terras indígenas como bens fora do comércio (TI Pequizal do Naruvôtu)

  MS 34.199 AgR

2020

- Manutenção de retirada de terceiros não indígenas de terra indígena e reassentamento (TI Apyterewa)
  SL 975 MC-ED-AgR
- Presunção da constitucionalidade do Decreto nº 1.775/1996, que dispôs sobre o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas (TI dos Guarani-Kaiowá)
  SS 4.243 AgR
- Proteção dos direitos dos povos indígenas à saúde, à vida e ao território durante a pandemia (Plano Geral de Enfrentamento à Covid-19 para Povos Indígenas)
  ADPF 709 MC-Ref
- Proteção do direito dos povos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas e Usina de Itaipu (indígenas da etnia Ava Guarani)
  SL 1.197 AgR
- Acesso à justiça e direito à participação de povos indígenas em processos judiciais que discutem a demarcação de suas terras (Comunidade Indígena do Povo Kaingang de Toldo Boa Vista)
  AR 2.750 MC-Ref

2021

- Acesso à justiça e garantia de participação de povos indígenas em processos judiciais que discutem demarcação de suas terras (Comunidade Indígena Guyraroká)
  AR 2.686 AgR
- Proteção dos direitos das comunidades quilombolas durante a pandemia (Plano de Enfrentamento da Covid-19 para os Povos Quilombolas Brasileiros)
  ADPF 742 MC
- Direito dos povos indígenas à terra e alegadas terras devolutas do Estado (Parque Indígena Grande Aripuanã)
  ACO 365
- Critérios para a validade de prova pericial relacionada à demarcação de terras indígenas (Parque Indígena do Aripuanã)
  ACO 365 AgR
- Direito dos povos indígenas à vida e à integridade pessoal durante a pandemia (TI Yanomami e Munduruku)
  ADPF 709 TPI-Ref
- Direito de acampamento indígena ao acesso à energia elétrica (Comunidade Indígena Guarani)
  ARE 1.321.559 AgR

- Rejeição da retirada de comunidades indígenas de área com indícios de ocupação tradicional (indígenas da etnia Terena, Terra Indígena Taunay Ipegue)

  SL 1.156 AgR

- Presunção de veracidade e legitimidade do ato de demarcação e direito à retirada de terceiros não indígenas (etnia Tapirapé, Terra Indígena Urubu Branco)

  SL 1.355 AgR-segundo

Legenda:

- Direito à Consulta Livre, Prévia e Informada
- Direito à Propriedade Coletiva
- Direitos Civis e Políticos
- Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais
- Direito e Economia
- Tutela Judicial Efetiva e Garantias Judiciais (Acesso à Justiça)

Jurisprudência do STF
• Regime constitucional para a demarcação de terras indígenas (Caso Raposa Serra do Sol). **[1]** • Tutela do direito dos povos quilombolas à terra e impossibilidade de sua outorga a terceiros. **[2]** • Constitucionalidade do Decreto 4.887/2003, que regulamentou a demarcação de territórios quilombolas. **[3]** • Regime jurídico constitucional aplicável às relações de posse indígena e à demarcação de suas terras. **[4]** • Acesso à justiça e exigência de coerência funcional aos órgãos que garantem a proteção dos direitos de povos tradicionais. **[5]** • Direito à consulta livre, prévia e informada. **[6]** • Imprescritibilidade de pretensão de reparação civil de dano ambiental (Comunidade Ashaninka-Kampa do Rio Amônia). **[7]** • Direito à propriedade coletiva comunal – indeferimento de pagamento de indenização por expropriação de propriedades reconhecidas como de ocupação tradicional (Reserva Indígena Ibirama-La Klanó).**[8]** • Descabimento de mandado de segurança para debater a posse indígena e terras indígenas como bens fora do comércio (Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu). **[9]** • Manutenção de retirada de terceiros não indígenas de terra indígena e reassentamento (Terra Indígena Apyterewa). **[10]** • Presunção da constitucionalidade do Decreto nº 1.775/1996, que dispôs sobre o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas (Terra Indígena dos Guarani-Kaiowá). **[11]** • Proteção dos direitos dos povos indígenas à saúde, à vida e ao território durante a pandemia (Plano Geral de Enfrentamento à Covid-19 para Povos Indígenas) **[12]** • Proteção do direito dos povos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas e Usina de Itaipu (indígenas da etnia Ava Guarani) **[13]** • Acesso à justiça e direito à participação de povos indígenas em processos judiciais que discutem a demarcação de suas terras (Comunidade Indígena do Povo Kaingang de Toldo Boa Vista) **[14]**

- Acesso à justiça e garantia de participação de povos indígenas em processos judiciais que discutem demarcação de suas terras (Comunidade Indígena Guyraroká). **[15]**
- Proteção dos direitos das comunidades quilombolas durante a pandemia (Plano de Enfrentamento da Covid-19 para os Povos Quilombolas Brasileiros). **[16]**
- Critérios para a validade de prova pericial relacionada à demarcação de terras indígenas (Parque Indígena do Aripuanã). **[17]**
- Direito dos povos indígenas à terra e alegadas terras devolutas do Estado (Parque Indígena Grande Aripuanã). **[18]**
- Direito dos povos indígenas à vida e à integridade pessoal durante a pandemia (Terras Indígenas Yanomami e Munduruku). **[19]**
- Direito de acampamento indígena ao acesso à energia elétrica (Comunidade Indígena Guarani). **[20]**
- Rejeição da retirada de comunidades indígenas de área com indícios de ocupação tradicional (indígenas da etnia Terena, Terra Indígena Taunay Ipegue). **[21]**
- Presunção de veracidade e legitimidade do ato de demarcação e direito à retirada de terceiros não indígenas (etnia Tapirapé, Terra Indígena Urubu Branco). **[22]**

[1] Pet 3.388: regime constitucional para a demarcação de terras indígenas (Caso Raposa Serra do Sol). Trata-se de ação popular, proposta em face da União, pedindo a declaração de nulidade do processo administrativo de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. O STF julgou improcedente o pedido, afirmando a constitucionalidade do processo de demarcação de terras. Entretanto, impôs condicionantes à sua delimitação e manutenção. O argumento central utilizado pelo Tribunal foi o direito constitucional à demarcação de terras indígenas previsto nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal. • **Pet 3.388 ED: regime constitucional para a proteção de terras indígenas e efeitos limitados ao caso (Caso Raposa Serra do Sol).** Trata-se de embargos de declaração em ação popular proposta contra a União pedindo a declaração de nulidade do processo administrativo de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. O STF julgou parcialmente procedente o pedido, esclarecendo pontos centrais da decisão.

[2] ADI 4.269: tutela do direito dos povos quilombolas à terra e impossibilidade de sua outorga a terceiros. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com impugnação aos artigos 4º, §2º, 13, 15, I, §§ 2º, 4º e 5º da Lei nº 11.952/2009, que dispõe sobre a regulari- zação fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal. O STF julgou parcialmente procedente o pedido, conferindo interpretação conforme à Constituição em relação aos artigos artigo 4º, §2º, e 13. Especificamente em relação aos territórios de comunidades quilombolas e de comunidades tradicionais, o argumento central foi a especial proteção aos territórios ocupados por povos com modos tradicionais de criar, fazer e viver.

[3] ADI 3.239: constitucionalidade do Decreto 4.887/2003, que regulamentou a demarcação de territórios quilombolas. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com impugnação ao Decreto 4.887/2003, que regulamenta a demarcação de territórios quilombolas. O STF julgou improcedente o pedido, reconhecendo a constitucionalidade do decreto. O argumento central foi a proteção constitucional aos territórios quilombolas, assegurada nos artigos 216 da Constituição Federal e 68 dos ADCTs, na Con- venção 169 da OIT, e na Convenção Americana de Direitos Humanos, de acordo com a interpretação realizada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

[4] RE 1.017.365 RG: regime jurídico constitucional aplicável às relações de posse indígena e à demarcação de suas terras. Trata-se de repercussão geral (Tema 1031) no recurso extraordinário, mediante a qual a Presidência do STF reconhece repercussão geral da questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. O recurso teve sua repercussão geral reconhecida e, por meio dele, o STF tende a revisitar alguns temas pertinentes ao regime jurídico aplicável aos povos indígenas, entre eles a teoria do marco temporal para a demarcação de terra indígenas.

[5] ADI nº 6.062 MC-Ref: acesso à justiça e exigência de coerência funcional aos órgãos que garantem a proteção dos direitos de povos tradicionais. Trata-se de referendo de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. A ação teve por objeto a inconstitucionalidade da Medida Provisória 870/2019, que

estabeleceu a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, transferindo o vínculo da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSG) ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A realocação ocasionaria potenciais interesses conflitantes com a tutela da terra indígena. O Pleno do STF referendou a cautelar deferida monocraticamente pelo Relator, por violação ao artigo 62, §10, da Constituição Federal. O argumento central que motivou o referendo foi a inconstitucionalidade formal da norma (é vedada a reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa), tendo-se seguido precedentes consolidados do STF na matéria. Contudo, argumentos de inconstitucionalidade material foram apresentados pelo Ministro Edson Fachin, em diálogo com o SIDH.

[6] SL 995 AgR: direito à consulta livre, prévia e informada. Trata-se de agravo regimental, tendo por objeto decisão da Presidente do STF que rejeitou pedido de suspensão de liminar. A liminar em questão ordenara a interrupção de obra de instalação de linha de transmissão de energia elétrica para que fosse realizado procedimento de consulta aos povos indígenas envolvidos. O Pleno do STF reverteu a decisão da Presidência da Corte, determinando a suspensão da liminar, ao fundamento de que a suspensão do licenciamento e das obras de construção da linha de transmissão elétrica, de forma abrupta, teriam o potencial de acarretar graves lesões à economia pública.

[7] RE 654.833: imprescritibilidade de pretensão de reparação civil de dano ambiental (Comunidade Ashaninka-Kampa do Rio Amônia). Trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral (tema 999) tendo por objeto acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferido em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF). Na referida ação, objetivou-se a reparação de danos materiais, morais e ambientais decorrentes de invasões de área indígena ocupada pela comunidade Ashaninka-Kampa do Rio Amônia. O STF reconheceu, na hipótese, a imprescritibilidade de pretensão de reparação civil de dano ambiental.

[8] SL 610 AgR-2º julg: direito à propriedade coletiva comunal – indeferimento de pagamento de indenização por expropriação de propriedades reconhecidas como de ocupação tradicional (Reserva Indígena Ibirama-La Klanó). Trata-se de agravo regimental, em suspensão de liminar, interposto contra decisão mediante a qual a Presidência do STF deferiu medida de contracautela, suspendendo o pagamento de indenização por expropriação de propriedade localizada em área de domínio da União (Reserva Indígena Ibirama-La Klanó, reconhecida pela Portaria do Ministério da Justiça nº 1.128/03 e cuja validade está sendo discutida na ACO nº 1.100). O STF negou provimento ao agravo regimental com fundamento na presunção de legitimidade e de veracidade do ato de demarcação e na grave lesão à economia pública, dado o elevado montante da indenização.

[9] MS 34.199 AgR: descabimento de mandado de segurança para debater a posse indígena e terras indígenas como bens fora do comércio (Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu). Trata-se de agravo regimental interno contra decisão do Ministro Relator que não conheceu de mandado de segurança impetrado com o objetivo de invalidar ato da Presidência da República consubstanciado em Decreto de 29 de abril de 2016. O referido decreto homologou a demarcação administrativa da Terra Indí- gena Pequizal do Naruvôtu (Estado de Mato Grosso). O STF negou provimento ao agravo regimental com fundamento na inadequação do uso de mandado de segurança para o caso, em virtude da necessidade de produção de prova e no princípio res extra commercium, que protege terras indígenas de uso comercial.

[10] SL 975 MC-ED-AgR: manutenção de retirada de terceiros não indígenas de terra indígena e reassentamento (Terra Indígena Apyterewa). Trata-se de agravo regimental em suspensão de liminar. A Presidência do STF deferiu pedido de suspensão de decisão que havia sido proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), sustando os efeitos de portaria de assen- tamento agrário emitida pelo INCRA, relacionada ao processo de extrusão de colonos não-indígenas da terra indígena Apyterewa. O agravo insurgiu-se contra a decisão que restabeleceu os efeitos da portaria de assentamento e extrusão de não-indígenas. O STF julgou improcedente o pedido veiculado no agravo, mantendo a decisão da Presidência. Reconheceu-se a existência de risco de grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas provocado pela interrupção do processo de regularização e extrusão da terra indígena Apyterewa.

[11] SS 4.243 AgR: presunção da constitucionalidade do Decreto nº 1.775/1996, que dispôs sobre o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas (Terra Indígena dos Guarani-Kaiowá).

Trata-se de agravo regimental em suspensão de segurança. A Presidência do STF deferiu pedido de contracautela contra decisão judicial liminar do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) que havia suspendido procedimentos de demarcação de terras indígenas pela FUNAI. A decisão da Presidência restabeleceu o processo de demarcação. Contra essa decisão opôs-se agravo regimental rejeitado pelo Pleno do STF. Reconheceu-se a presunção de constitucionalidade do Decreto nº 1.775/96, que dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, bem como a relevância da demarcação de terras indígenas, conforme art. 231 da Constituição Federal.

[12] ADPF 709 MC-Ref: proteção dos direitos dos povos indígenas à saúde, à vida e ao território durante a pandemia (Plano Geral de Enfrentamento à Covid-19 para Povos Indígenas). Trata-se de referendo de medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental tendo por objeto a violação a direitos fundamentais das comunidades indígenas em tempos de pandemia. O STF julgou procedente o pedido para ordenar a adoção de uma série de políticas públicas de proteção aos povos indígenas. O argumento central foi a proteção constitucional dos direitos à saúde e dos povos indígenas, além do cumprimento a normas internacionais que regem a questão.

[13] SL 1.197 AgR: proteção do direito dos povos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas e Usina de Itaipu (indígenas da etnia Ava Guarani). Trata-se de agravo regimental em sede de suspensão de liminar e de tutela provi- sória. No caso, a Presidência do STF deferiu medida de contracautela, objetivando sustar os efeitos de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu (Seção Judiciária do Paraná). Tal decisão determinara a reintegração na posse, em favor de Itaipu Binacional, de imóveis que teriam sido invadidos por indígenas da etnia Ava Guarani. A Presidência suspendeu a reintegração na posse, decisão contra a qual se opôs agravo regimental. O Pleno do STF negou provimento ao agravo regimental, com fundamento na provável ocupação tradicional da área objeto do litígio e no risco à ordem pública que o cumprimento das ordens de desintrusão de indígenas poderia causar.

[14] AR 2.750 MC-Ref: acesso à justiça e direito à participação de povos indígenas em processos judiciais que discutem a demarcação de suas terras (Comunidade Indígena do Povo Kaingang de Toldo Boa Vista). Trata-se de referendo de medida cautelar concedida no âmbito de ação rescisória. A cautelar suspendeu os efeitos de decisão judicial transitada em julgado que anulou a demarcação de terra indígena. O Pleno do STF referendou a medida cautelar, suspendendo os efeitos da coisa julgada. O argumento central foi a pre- sença simultânea de fumus boni iuris (em virtude da não citação das comunidades indígenas interessadas no processo de demarcação) e de periculum in mora.

[15] AR 2.686 AgR: acesso à justiça e garantia de participação de povos indígenas em processos judiciais que discutem demarcação de suas terras (Comunidade Indígena Guyraroká). Trata-se de agravo regimental em ação rescisória. O agravo teve por objeto deci- são monocrática do STF que negou seguimento à ação rescisória, por meio da qual se pretendia rescindir decisão que declarou nulo processo administrativo de demarcação de terras indígenas. O Pleno do STF deu provimento ao agravo para dar seguimento à ação rescisória. Invocaram-se os direitos de acesso à justiça e ao reconhecimento de personalidade jurídica às comunidades indígenas, conforme artigos 5º, XXXV, 231 e 232 da Constituição Federal.

[16] ADPF 742: proteção dos direitos das comunidades quilombolas durante a pandemia (Plano de Enfrentamento da Covid-19 para os Povos Quilombolas Brasileiros). Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental tendo por objeto a violação a direitos fundamentais das comunidades quilombolas durante a pan- demia da covid-19. O STF julgou procedente o pedido, com base no fundamento de proteção constitucional ao direito à saúde e às comunidades quilombolas.

[17] ACO 365 AgR: critérios para a validade de prova pericial relacionada à demarcação de terras indígenas (Parque Indígena do Aripuanã). Trata-se de agravo regimental no âmbito de ação cível originária. O agravo teve por objeto decisão monocrática que rejeitou a alegação de nulidade da perícia realizada em primeiro grau e assentou a desnecessidade de complementação da prova técnica. O Pleno do STF negou provimento ao agravo regimental e observou que a valoração do laudo pericial, seja sob o aspecto histórico, arqueológico ou antropológico, é matéria a ser resolvida quando da análise do mérito da demanda concernente à demarcação de terras indígenas.

[18] ACO 365: direito dos povos indígenas à terra e alegadas terras devolutas do Estado (Parque Indígena Grande Aripuanã). Trata-se de ação cível originária, tendo por objetivo obter indenização, por desa-

propriação indireta, de alegadas terras devolutas estaduais que teriam sido esbu- lhadas pelas rés para compor o perímetro do Parque Indígena do Aripuanã. O STF julgou os pedidos improcedentes, com base no fundamento de que há prova da presença tradicional indígena na Área Indígena Grande Aripuanã (Parque Indígena Grande Aripuanã) e de que não há prova de que ditas áreas foram incorporadas ao patrimônio imobiliário do Estado de Mato Grosso na condição de terras devolutas.

[19] ADPF 709 TPI-Ref: direito dos povos indígenas à vida e à integridade pessoal durante a pandemia (Terras Indígenas Yanomami e Munduruku). Trata-se de referendo em tutela provisória incidental em arguição de descumpri- mento de preceito fundamental tendo por objeto a proteção de povos indígenas contra conflitos violentos, presença de invasores, garimpo ilegal e contágio por covid-19 nas Terras Indígenas Yanomami e Munduruku. O STF deferiu pedido de tutela antecipada incidental para determinar à União a adoção imediata de todas as medidas necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança das populações indígenas. Os argumentos centrais para o deferimento foram: (i) o princípio da precaução e (ii) a relação entre a tutela antecipada postulada e a medida cautelar já ordenada no âmbito da ADPF.

[20] ARE 1.321.559 AgR: direito de acampamento indígena ao acesso à energia elétrica (Comunidade Indígena Guarani). Trata-se de agravo regimental tendo por objeto decisão mediante a qual se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. O STF negou provimento ao agravo regimental com fundamento na inadequação do recurso extraordinário como instrumento para revisão de prova ou debate de matéria infraconstitucional, reconhecendo possibilidade de o poder judiciário determinar, em situações excepcionais, a adoção de medidas que garantam direitos constitucionais (no caso, acesso de acampamento indígena à energia elétrica).

[21] SL 1.156 AgR: rejeição da retirada de comunidades indígenas de área com indícios de ocupação tradicional (indígenas da etnia Terena, Terra Indígena Taunay Ipegue). Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STF que deferiu pedido de suspensão de liminar, formulado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A PGR requereu a sustação dos efeitos de decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) determinando a retirada de comunidades indígenas de determinadas áreas. O agravo voltou-se contra a decisão da Presidência que suspendeu a retirada. O Pleno do STF negou provimento ao agravo regimental com fundamento na plausibilidade da existência de ocupação tradicional da área por indígenas da etnia Terena e na existência de perigo de grave lesão à ordem pública.

[22] SL 1.355 AgR-segundo: presunção de veracidade e legitimidade do ato de demarcação e direito à retirada de terceiros não indígenas (etnia Tapirapé, Terra Indígena Urubu Branco). Trata-se de agravo interno oposto contra decisão mediante a qual a Presidência do STF deferiu suspensão de medida liminar. Na prática, a decisão da Presidência restabeleceu ordem de desocupação de terceiros não-indígenas da Terra Indígena Urubu Branco. O Pleno do STF negou provimento ao agravo regimental, mantendo a desocupação de terceiros, com fundamento na presunção de legitimidade e de veracidade do ato de demarcação.

Caderno de jurisprudência do STF: Direitos dos Povos Indígenas e Quilombolas	Material disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório https://www.proleges.com.br/
• Cada julgado retromencionado da Jurisprudência do STF está sistematizado neste material gratuito. • Vale conferir o material (publicado em abr/2023).	

Legislação
• **Global: i)** Declaração das Nações Unidades sobre Direitos dos Povos Indígenas; **[1]** e **ii)** Convenção 169 da OIT. **[2]** • **Interamericano:** não há tratado específico no sistema interamericano, mas já existe jurisprudência. • **Constitucional:** CF/88 e jurisprudência do STF • **Legal:** o Estatuto do Índio é criticado por ser baseado na integração (parte do pressuposto de inferioridade do indígena).

☑ **(Procurador da República MPF 2017 correta)** A Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas prevê que o Estado deve obter o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas antes da adoção de medidas administrativas ou legislativas que os afetem.

[1] A Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas é de natureza ***soft law*** **(não vinculante)**, pois não tem natureza de tratado internacional de direitos humanos.

[2] A Convenção 169 da OIT detém natureza de tratado internacional (***hard law*** / vinculante) e foi incorporado na ordem jurídica interna brasileira (Decreto 10.088/2019).

Convenção 169 da OIT (Decreto 10.088/2019)
Artigo 6º 1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão: a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;

☑ **(Juiz TRT14 2012 correta)** O Brasil, de acordo com a Convenção nº 169 da OIT, deverá consultar os povos indígenas, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, por meio das instituições indígenas representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente.

☑ **(Juiz Federal TRF3R 2022 correta)** É possível haver compatibilidade entre meio ambiente e terras indígenas, ainda que estas envolvam áreas de conservação ambiental e/ou áreas de preservação ambiental. Esta compatibilidade é que autoriza a dupla afetação, sob a administração do competente órgão ambiental, devendo-se observar a Convenção nº 169 da OIT, especialmente quanto à necessidade da consulta livre, prévia e informada dos povos indígenas na elaboração do plano de administração conjunta ou gestão compartilhada do espaço ambientalmente protegido.

☑ **(Juiz Federal TRF3R 2022 correta)** O Estado deverá zelar para sejam efetuados estudos junto aos povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, com o objetivo de se avaliar a incidência social, espiritual e cultural que as atividades submetidas ao licenciamento ambiental possam ter sobre esses povos e comunidades.

☑ **(Juiz Federal TRF3R 2022 correta)** Cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetar os povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, é dever do Estado lhes garantir o direito de consulta livre, prévia e informada.

☑ **(Defensor DPEAC 2017 Cespe correta)** Conforme disposição da OIT, os povos indígenas deverão ser consultados sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas capazes de afetá-los diretamente.

☑ **(Defensor DPETO 2022 Cespe correta)** Considerando a Convenção 169 da OIT, os quilombolas são grupos culturalmente diferenciados da grande sociedade e se reconhecem como tais, apesar de não corresponderem exatamente ao conceito de povos tribais, tampouco ao de indígenas.

☑ **(Defensor DPEPA 2022 Cespe correta)** A Convenção 169 da OIT deve ser aplicada a questões de ordem penal relativas aos povos indígenas.

☑ **(Analista PGEBA 2013 FCC correta)** Para os fins da Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, são considerados indígenas os povos que descenderem de

populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas.

☑ **(Procurador MPT 2012 correta)** A Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, conhecida como Convenção 169 da OIT, foi ratificada pelo Brasil. Entre outros aspectos ela trata da contratação e condições de emprego e estatui que os governos devem adotar medidas para prevenir qualquer discriminação entre trabalhadores pertencentes a estes povos.

☑ **(Defensor DPERJ 2021 FGV correta)** O Rio de Janeiro tem assistido ao incremento da violência e da intensidade de ataques a terreiros/casas religiosas de matrizes africanas. Além da violência física e psicológica contra os religiosos, as casas têm sido invadidas, incendiadas, os artefatos sagrados quebrados e, em alguns casos, os membros são expulsos de suas casas e impedidos de retornar. Quando muito, as vítimas conseguem registrar as violências como violação de domicílio, constrangimento ilegal, dano e furto. Para garantir maior proteção junto ao sistema interno e internacional de direitos humanos: pode ser mobilizada a Convenção 169 da OIT, pois os terreiros possuem formas próprias de organização social, ocupando e usando territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica.

CF/88
Art. 20. São bens da União: XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos **índios**.
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XIV - populações **indígenas**;
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: XVI - autorizar, em **terras indígenas**, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: XI - a disputa sobre **direitos indígenas**.
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: V - defender judicialmente os direitos e interesses das **populações indígenas**;
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. § 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou **terras indígenas**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. § 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às **comunidades indígenas** também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, **indígenas** e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
CAPÍTULO VIII **DOS ÍNDIOS**

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.
§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 231 DA CF/88	
TEORIA DO INDIGENATO	**TEORIA DO FATO INDÍGENA (OU DO MARCO TEMPORAL)** (adotada pelo STF)
• A legitimação da posse das terras pelos indígenas decorreria de sua propriedade *tradicional* ou *imemorial* (aspecto antropológico). • A posse decorre da persistência histórica da ocupação de determinado território pelos povos indígenas. • É a teoria adotada pelos povos indígenas e pela Corte IDH (ex: Caso Comunidade Indígena Sawhoyamaxa).	• A legitimação da posse decorre do fato de os indígenas estarem na posse das terras na data da promulgação da Constituição de 1988, prevalecendo a segurança jurídica. Logo, a legitimação da posse decorre da própria promulgação da CF/88. • É a teoria adotada pelo STF no julgamento da Petição 3.388 (Caso Raposa Serra do Sol).

➥ Está pendente no **STF o RE 1.017.365 (com repercussão geral)**. O Plenário voltará a discutir qual teoria adotou.

Acompanhar o RE 1.017.365

TERRAS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	
COMUNIDADES INDÍGENAS	**COMUNIDADES QUILOMBOLAS**
• Art. 231 da CF/88. • Possuem apenas a posse. • Propriedade é da União (art. 20, XI, CF/88).	• Art. 68 do ADCT. **[1]** • Possuem a propriedade de suas terras.

[1] ADCT, art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é **reconhecida a propriedade definitiva**, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

Súmula 140-STJ	Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima.

Súmula 650-STF	Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto.

➥ Segundo critério construído pelo STF, somente são consideradas "terras tradicionalmente ocupadas pelos índios" aquelas que eles habitavam na **data da promulgação da CF/88 (marco temporal) e, complementarmente, se houver a efetiva relação dos índios com a terra (marco da tradicionalidade da ocupação)**. Assim, se, em 05/10/1988, a área em questão não era ocupada por índios, isso significa que ela não se revestirá da natureza indígena de que trata o art. 231 da CF/88.

➥ As terras ocupadas, em passado remoto, por aldeamentos indígenas não são bens da União (STF AI-AgR 307401/SP).

Jurisprudência nacional

DIREITO CONSTITUCIONAL – REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS; PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE; MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO; ORDEM SOCIAL; ÍNDIOS; PROTEÇÃO DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS; COMUNIDADES TRADICIONAIS E REMANESCENTES QUILOMBOLAS.
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; CONCESSÃO.
DIREITO AMBIENTAL – LICENCIAMENTO AMBIENTAL; RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
CONCESSÃO DE ÁREAS ESTADUAIS PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES DE ECOTURISMO E EXTRAÇÃO COMERCIAL DE MADEIRA E SUBPRODUTOS FLORESTAIS.
1. É constitucional norma estadual que, sem afastar a aplicação da legislação nacional em matéria ambiental (inclusive relatório de impacto ambiental) e o dever de consulta prévia às comunidades indígenas e tradicionais, quando diretamente atingidas por ocuparem zonas contíguas, autoriza a concessão à iniciativa privada da exploração de serviços ou do uso de bens imóveis do Estado;
2. A concessão pelo Estado não pode incidir sobre áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, remanescentes quilombolas e demais comunidades tradicionais.
STF. Plenário. ADI 7.008/SP, relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 19/5/2023 (Info 1095).

➥ É constitucional lei estadual que autoriza à iniciativa privada a concessão da exploração dos serviços ou do uso de áreas inerentes ao ecoturismo e à exploração comercial de madeireira ou de subprodutos florestais, desde que respeite a legislação ambiental federal e não incida sobre áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, remanescentes quilombolas e demais comunidades tradicionais.

➥ A lei estadual impugnada disciplina as condições e os requisitos mínimos para a outorga das concessões à iniciativa privada da exploração de serviços ou do uso de bens imóveis locais. Desse modo, a norma não afasta a incidência de normas de proteção ambiental, de caráter geral, editadas pela União, que compreendem a obrigatoriedade de licenciamento para empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras. Ademais, ela também observa o estatuto protetivo da população indígena, que inclui o dever constitucional de consulta prévia às comunidades indígenas e tradicionais diretamente afetadas **(1)**.

➥ Entretanto, **se a concessão ocorrer em território indígena, estará eivada de inconstitucionalidade, por se tratar de área pertencente à União** (CF/1988, art. 20, XI) **e de usufruto exclusivo dos índios** (CF/1988, art. 231). **Da mesma forma, as áreas ocupadas por comunidades tradicionais e de remanescentes quilombolas não podem ser cedidas à iniciativa privada** (ADI 4269). Isso porque elas utilizam suas terras não só como moradia, mas como elo que mantém a união do grupo e que permite a sua continuidade no tempo por sucessivas gerações, de modo a possibilitar a preservação de sua identidade, cultura, valores e maneira de viver (CF/1988, arts. 215 e 216; ADCT, art. 68; e Convenção 169 da OIT, arts. 13 e 14), sendo indiferente a fase em que se encontram a regularização fundiária ou a demarcação e proteção das terras.

➥ Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme a Constituição à Lei 16.260/2016 do Estado de São Paulo, no sentido de afastar de sua incidência as terras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, remanescentes quilombolas e demais comunidades tradicionais.
(1) CF/1988: "Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 39emarca-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. § 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. § 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. § 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, 'ad referendum' do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. § 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. § 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º."

A sobreposição da propriedade rural com área indígena, ainda que o processo de demarcação não tenha sido concluído, inviabiliza a certificação de georreferenciamento

Caso hipotético: João, proprietário de uma fazenda, realizou o georreferenciamento de seu imóvel rural e, em seguida, solicitou ao INCRA a atualização cadastral e a certificação das peças técnicas (planta e memorial descritivo), decorrentes para atender as exigências da Lei 10.267/2001. O INCRA, contudo, recusou-se a fazer a certificação sob o argumento de que a fazenda estaria sobreposta a uma reserva indígena.

A recusa do INCRA foi correta mesmo se a área indígena ainda não tiver sido demarcada.

As terras ocupadas pelos indígenas são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis (§ 4º do art. 231 da CF/88). Não pode a Administração ser compelida a certificar situação imobiliária em descumprimento da lei e Constituição, pois são nulos os títulos particulares sobre terras indígenas, a teor do § 6º do art. 231 da CF/88.

STJ. 2ª Turma. AREsp 1640785-MS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 25/10/2022 (Info 755).

A comunidade indígena cuja posse é questionada em ação de nulidade de demarcação deve ser considerada como litisconsorte passiva necessária

A comunidade indígena cuja posse fundiária é questionada em ação de nulidade de demarcação tem o direito subjetivo de ser ouvida no processo, na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

STJ. 2ª Turma. AgInt na Pet no REsp 1586943-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17.05.2022 (Info 737).

O Poder Judiciário pode determinar, ante injustificável inércia estatal, que o Poder Executivo adote medidas necessárias à concretização de direitos constitucionais dos indígenas

Caso concreto: MPF ajuizou ACP contra a União e a FUNAI para que concluíssem o Processo Administrativo instaurado pelo Grupo Indígena Fulkaxó, no prazo de 4 meses, a contar da intimação da sentença, bem como para destinar área à posse e ocupação dessa tribo, no prazo de 1 ano, ante a impossibilidade de convivência pacífica com os índios da etnia Kariri-Xocó (de quem os primeiros se originam), nas terras originariamente demarcadas pela administração pública.

STJ. 1ª Turma.REsp 1623873-SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/04/2022 (Info 734).

É necessário que a União e a FUNAI executem e implementem atividade de proteção territorial nas terras indígenas, independentemente de sua homologação

Nos termos do art. 231 da Constituição Federal, a União tem o dever (e não a escolha) de demarcar as terras indígenas. Tais demarcações deveriam estar concluídas no prazo de 5 anos, contados da promulgação da Constituição, conforme art. 67 do ADCT.

A não homologação das demarcações dessas terras deriva de inércia deliberada do Poder Público, em afronta ao direito originário dos índios.
Ao afastar a proteção territorial em terras não homologadas, a FUNAI sinaliza a invasores que a União se absterá de combater atuações irregulares em tais áreas, o que pode constituir um convite à invasão de terras que são sabidamente cobiçadas por grileiros e madeireiros, bem como à prática de ilícitos de toda ordem. Além disso, a suspensão da proteção territorial abre caminho para que terceiros passem a ali transitar, o que põe em risco a saúde dessas comunidades, expondo-as a eventual contágio por COVID-19 e outras enfermidades.
STF. Plenário. ADPF 709-MC-segunda-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/2/2022 (Info 1045).

STF determina que governo federal adote medidas para conter o avanço da Covid-19 entre indígenas
A associação "Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e seis partidos políticos ajuizaram arguição de descumprimento de preceito fundamental alegando que o Poder Público estava falhando na proteção dos povos indígenas com relação à pandemia da Covid-19.
Os autores apontaram uma série de atos comissivos e omissivos do Poder Público que, segundo eles, estavam causando alto risco de contágio e de extermínio dos povos indígenas.
Os requerentes apontaram que tais atos violam a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), o direito à vida (art. 5º, caput) e o direito à saúde (arts. 6º e 196), além do direito de tais povos a viverem em seu território, de acordo com suas culturas e tradições (art. 231).
Na ação, os autores pedem a realização de diversas medidas necessárias para a proteção dos povos indígenas.
O Min. Roberto Barroso (relator) deferiu parcialmente a medida cautelar para que a União implemente, em resumo, as seguintes providências:
Quanto aos povos indígenas em isolamento ou povos indígenas de recente contato:
1. Criação de barreiras sanitárias, que impeçam o ingresso de terceiros em seus territórios;
2. Criação de Sala de Situação, para gestão de ações de combate à pandemia quanto aos Povos Indígenas em Isolamento e de Contato Recente.
Quanto aos povos indígenas em geral:
1. Inclusão de medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores em relação às comunidades indígenas ou providência alternativa, apta a evitar o contato.
2. Imediata extensão dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde.
3. Elaboração e monitoramento de um Plano de Enfrentamento da COVID-19 para os Povos Indígenas Brasileiros pela União.
O Plenário do STF referendou a medida cautelar concedida.
STF. Plenário. ADPF 709 Ref-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3 e 5/8/2020 (Info 985).

Não se exige que eventuais interessados na remarcação das terras indígenas sejam notificados diretamente a respeito da existência do procedimento
A demarcação de terras indígenas é realizada mediante processo administrativo disciplinado pelo Decreto nº 1.775/96.
Este Decreto não exige que eventuais interessados na demarcação (ex: pessoas que possuem títulos de propriedade da área a ser demarcada) sejam notificados diretamente a respeito da existência do procedimento.
Basta que seja publicado um resumo do relatório circunstanciado nos Diários Oficiais da União e da unidade federada onde se encontra a área sob demarcação - publicação essa que também deve ser afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel (art. 2º, § 7º do Decreto nº 1.775/96). Isso já é suficiente para garantir o contraditório.
Vale ressaltar, no entanto, que nesta publicação deverá constar o nome do interessado ou de sua propriedade rural (ex: Fazenda Terra Boa).
Assim, não há nulidade em processo de remarcação de terras indígenas por ausência de notificação direta a eventuais interessados, bastando que a publicação do resumo do relatório circunstanciado seja afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel.

STJ. 1ª Seção.MS 22816-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/9/2017 (Info 611).

Levantamento da área a ser demarcada em procedimento de demarcação de terras indígenas

O procedimento de demarcação das terras indígenas é regulado pelo Decreto 1.775/96, que estabelece, em seu art. 2º, a necessidade de ser elaborado um estudo técnico antropológico e levantamento da área demarcada.

A realização da etapa de levantamento da área a ser demarcada é imprescindível, ainda que já tenham sido realizados trabalhos de identificação e delimitação da terra indígena de maneira avançada.

O descumprimento dessa etapa configura violação do devido processo legal administrativo e enseja vício de nulidade da demarcação.

STJ. 2ª Turma. REsp 1551033-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/10/2015 (Info 571).

Caso Raposa Serra do Sol

Principais pontos decididos pelo STF no julgamento dos embargos de declaração:

1) Pessoas miscigenadas, ou que vivam maritalmente com índios, podem permanecer na área.

2) Presença de autoridades religiosas e templos: cabe às comunidades indígenas o direito de decidir se, como, e em quais circunstâncias seria admissível a presença dos missionários e seus templos.

3) Escolas públicas: as entidades federadas devem continuar a prestar serviços públicos nas terras indígenas, desde que sob a liderança da União (CF, art. 22, XIV).

4) Passagem de não índios pelas rodovias: os índios não exercem poder de polícia e não podem obstar a passagem de outras pessoas pelas vias públicas que cruzem a área demarcada.

5) Ações individuais: quanto às ações individuais que questionam a boa-fé dos portadores de títulos de propriedade, proveu-se o recurso para explicitar que ao STF não foram submetidos outros processos a respeito de questões individuais relacionadas à área, devendo eles ainda serem julgados pelos juízes naturais.

6) Posse das fazendas desocupadas: eventuais disputas do tipo devem ser resolvidas pelas comunidades interessadas, com a participação da FUNAI e da União, sem prejuízo da intervenção do Ministério Público e do Judiciário.

7) Condições estipuladas na decisão: as condições integram o objeto da decisão e fazem coisa julgada material. Portanto, tais diretrizes não podem ser objeto de questionamento em outros processos. Isso não significa transformação da coisa julgada em ato normativo geral e abstrato, vinculante para outros processos que discutam matéria similar. Em outras palavras, essas condições estipuladas para a Raposa Serra do Sol não vinculam os juízes e tribunais quando forem julgar questões envolvendo outras terras indígenas.

Vale ressaltar, entretanto, que é natural que o entendimento do STF sobre o tema sirva de força argumentativa para outros casos semelhantes.

STF. Plenário. Pet 3388 ED — Terceiros/RR, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 23/10/2013 (Info 725).

➥ Buscador Dizer o Direito: https://bit.ly/3Mqn5Lh.

Usucapião indígena
(art. 33 da Lei 6.001/73 – Estatuto do Índio)

Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por **10 anos** consecutivos, trecho de terra inferior a cinqüenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da União, ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de que trata esta Lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupo tribal.

☑ **(Procurador PGEAP 2018 FCC correta)** Adquire a propriedade pela usucapião o índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por dez anos consecutivos, trecho de terra inferior a cinquenta hectares.

Comunidades indígenas e outras comunidades tradicionais
(Corte IDH)

Alguns casos da Corte IDH:
• **Caso Aloeboetoe e outros vs. Suriname:** foi o primeiro caso envolvendo direito dos povos indígenas na Corte IDH.
• **Caso Comunidade Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguai:** a Corte IDH considerou os **vínculos espirituais de ancestralidade** dos povos indígenas com o território para conferir o direito à recuperação de suas terras. O que nos leva a entender que a Corte IDH adota a **teoria do Indigenato** no tocante ao reconhecimento de terras indígenas.
• **Caso Comunidade Moiwana vs. Suriname:** um ponto importante no caso foi o chamado "**dano espiritual**" (**direito a um projeto pós-vida**), que seria uma forma agravada do dano moral, implicando nas crenças do destino da humanidade e suas relações com os mortos.
O caso também tratou sobre o fenômeno do esverdeamento dos direitos humanos (*greening*).
Também se entendeu que o território ancestral não é meramente uma questão de posse e propriedade, mas sim elemento material e espiritual.
• **Caso Comunidade Indígena Yakye Axa vs. Paraguai:** a Corte IDH que ambos, o direito à propriedade privada e o **direito de propriedade comunal indígena**, devem ser protegidos pelo art. 21 da CADH.
No caso, houve o deslocamento forçado da comunidade para viver em local diverso e inadequado, sem dignidade, gerando até mesmo morte.
• **Caso Povos Kaliña e Lokono vs. Suriname:** para a Corte IDH, é convencional o fenômeno da "**dupla afetação das terras indígenas**", ou seja, que consiste em **compatibilizar a proteção**, **em uma mesma propriedade**, dos **direitos ambientais** e dos **direitos das comunidades tradicionais**.
No mesmo sentido, o STF (Pet 3.388) entendeu pela constitucionalidade da "dupla afetação das terras indígenas". A Lei 9.985/2000 regula na ordem jurídica interna as chamadas unidades de conservação.
☑ **(Juiz Federal TRF3R 2022 correta)** É possível haver compatibilidade entre meio ambiente e terras indígenas, ainda que estas envolvam áreas de conservação ambiental e/ou áreas de preservação ambiental. Esta compatibilidade é que autoriza a dupla afetação, sob a administração do competente órgão ambiental, devendo-se observar a Convenção nº 169 da OIT, especialmente quanto à necessidade da consulta livre, prévia e informada dos povos indígenas na elaboração do plano de administração conjunta ou gestão compartilhada do espaço ambientalmente protegido.
• **Caso Povo Indígena Xucuru vs. Brasil:** a Corte IDH flexibiliza o conceito tradicional de posse e propriedade quando se fala em terras indígenas, privilegiando a **imemorialidade** e os antepassados dos povos indígenas. Assim, a Corte IDH adotou **interpretação extensiva do art. 21 da CADH** e reconheceu a relação imemorial das comunidades indígenas e seus territórios.
• **Caso Lhaka Honhat vs. Argentina:** a Corte IDH atrelou o direito à alimentação adequada e à água potável ao direito à identidade cultural dos povos indígenas, conferindo proteção por meio do art. 26 da CADH (judicialização direta dos direitos ambientais).
• **Caso Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingi vs. Nicarágua**: primeiro caso da Corte IDH sobre comunidades tradicionais e a propriedade de suas terras; extensão do art. 21 da CADH para proteger a propriedade comunal dos povos indígenas.
• **Caso Chacina Plan de Sánchez vs. Guatemala:** o caso se refere à cachina de 268 pessoas (a maioria membros da comunidade indígena Plan de Sánchez) e a falta de investigação e sanção dos responsáveis. A Corte IDH decidiu que não é possível o Estado aplicar lei de anistia, prescrição ou outra medida para afastar a responsabilidade dos agentes/responsáveis. A falta de processo e investigação importou em fixação de dano moral em favor das vítimas por parte da Corte IDH.
• **Caso do Povo Saramaka vs. Suriname:** não é necessária a autorização do líder da comunidade para provocar o sistema interamericano.
• **Caso Povo Indígena Kichwa Sarayaku vs. Equador:** possível utilizar a Convenção 169 da OIT como vetor interpretativo; o direito de consulta às comunidades indígenas deve ser prévio, livre e de boa-fé.

Medidas cautelares (CIDH):
• **Caso Comunidades Indígenas da Bacia do Rio Xingu vs. Brasil ("Caso Belo Monte"):** o caso envolve a construção da usina hidrelétrica (UHE) de Belo Monte na Bacia do Rio Xingu. Em síntese, houve violação do direito de consulta das comunidades indígenas, violando o art. 6º da Convenção 169 da OIT. A CIDH e a Corte IDH entendem que o direito de consulta às comunidades tradicionais é vinculante. O caso ainda está

na CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos). A CIDH determinou suspender o processo de licenciamento do projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, mas o Estado brasileiro se recusou.

Questões:
☑ **(Defensor DPEPA 2015 FMP correta)** Consoante o julgamento do caso Sarayaku versus Equador, os Estados devem consultar os povos indígenas, com a finalidade de obter acordo ou consentimento, antes de tomar qualquer decisão ou praticar qualquer ato estatal sobre assuntos que influenciam ou podem influenciar a vida cultural e social desses povos, de acordo com seus valores, usos, costumes e suas formas de organização.
☑ **(Juiz Federal TRF4R 2022 correta)** De acordo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos: i) as comunidades indígenas são titulares do direito de propriedade sobre os seus territórios; ii) os povos indígenas têm direito à duração razoável tanto dos processos administrativos de reconhecimento, titulação, demarcação e delimitação de suas propriedades territoriais indígenas quanto do processo de desintrusão das pessoas não indígenas que se encontram em seus territórios; iii) os Estados devem consultar ativamente e de maneira fundamentada os povos indígenas interessados antes de adotar e aplicar medidas legislativas e administrativas que os afetem. Além disso, as consultas devem realizar-se de boa-fé, por meio de procedimentos culturalmente adequados, e devem ter por finalidade chegar a um acordo.
☑ **(Técnico DPERJ 2019 FGV correta)** Em março de 2018, o Brasil sofreu uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos porque o Estado brasileiro atuou de forma lenta e inadequada na demarcação da terra do povo indígena Xukuru, em Pernambuco. A responsabilidade do Brasil em realizar as reparações determinadas pela Corte, com base na Convenção Americana de Direitos Humanos, recai sobre: o Governo Federal do Brasil – União – pois, como Estado Parte, cabe a ele assumir a responsabilidade pela Convenção.
☑ **(Procurador da República MPF 2022 correta)** No caso "Povo Indígena Xucuru e seus Membros" a Corte considerou o Estado brasileiro responsável pela violação do direito à garantia de prazo razoável na demarcação do território do Povo Indígena Xucuru.
☑ **(Defensor DPEPI 2022 Cespe correta)** A violação do direito à propriedade coletiva e à garantia e proteção judicial de comunidades indígenas acarretou a condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Povo Indígena Xucuru e Seus Membros vs. Brasil, cuja sentença evidenciou a imperiosa necessidade de as instituições brasileiras tutelarem e assegurarem os direitos dos povos tradicionais e originários.
☑ **(Defensor DPESP 2023 correta)** O direito à identidade cultural de povos indígenas foi atrelado ao direito à alimentação adequada, no caso Lhaka Honhat vs. Argentina, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
☑ **(Promotor MPESE 2022 Cespe correta)** No que se refere ao caso Povo Indígena Xucuru e seus Membros, o sistema interamericano interpretou, de forma extensiva, o direito de propriedade em relação aos povos indígenas, levando em consideração, entre outras características, a imemorialidade.

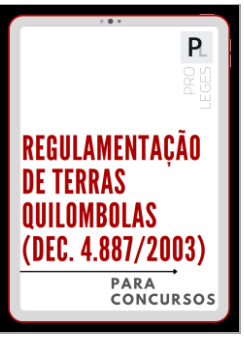
OC 22/2016
• **Em regra, as pessoas jurídicas não podem acessar o sistema interamericano de direitos humanos, exceto comunidades indígenas e sindicatos.**

OC 23/2017
• A partir do Caso Lagos del Campo, a Corte IDH passou a admitir a **judicialização direta dos direitos ambientais** (art. 26 da CADH é norma autônoma/independente). Esse entendimento foi reiterado na OC 23/2017. ☑ **(Defensor DPEAM 2018 FCC correta)** A primeira vez em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos desenvolveu de forma detalhada o conteúdo "direito ao meio ambiente sadio", inclusive reconhecendo os

direitos de acesso à informação, participação pública e acesso à justiça em matéria ambiental, foi no âmbito da Opinião Consultiva OC-23/17.
☑ **(Procurador MPT 2022 correta)** A respeito da Opinião Consultiva 23/2017, a Corte Interamericana conclui que os Estados têm a obrigação de garantir o direito do acesso à informação relacionada com possíveis afetações ao meio ambiente, além do direito à participação pública das pessoas sob sua jurisdição na tomada de decisões e políticas que podem afetar o meio ambiente.

O que se entende por *GREENING* (fenômeno do ESVERDEAMENTO dos direitos humanos)?
• Trata-se de um fenômeno que consiste na proteção dos direitos ambientais nos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. • No Caso Comunidade Moiwana vs. Suriname (2006), momento àquele em que a Corte IDH não entendia ainda pela aplicação direta do art. 26 da CADH, houve um chamado *esverdeamento* dos direitos humanos, pois naquela oportunidade a Corte IDH aplicou indiretamente a proteção dos direitos ambientais. Depois (em 2017), é importante falar, a Corte IDH avançou sobre o tema, adotando a judicialização direta dos direitos ambientais (OC 23/2017). ☑ **(Defensor DPEAP 2018 FCC correta)** A respeito do Greening ou "Esverdeamento" dos direitos humanos, as normas de proteção ambiental foram aplicadas indiretamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para a proteção de direitos civis e políticos no Caso Comunidade Moiwana vs. Suriname.

Decreto 10.088/2019 (Convenção 169 da OIT)	**Material disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório https://www.proleges.com.br/**	
• Comentamos e está disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório.		

Decreto 4.887/2003 (regulamentação de terras quilombolas)	**Material disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório https://www.proleges.com.br/**	
• Comentamos e está disponível na pasta de Direito Antidiscriminatório.		

Clique aqui para voltar ao SUMÁRIO